

刑法不作為犯保證人地位法理基礎的反思^{*}

—— 在存有和規範之間

黃奕文^{**}

摘要

本文討論刑法保證人地位實質根據的問題。我國刑法第15條是不作為犯的處罰依據，然而其並未表明具有何種身分或地位之人方能被課予不作為犯之刑責，學說上因而發展出實質的判斷標準來認定行為人之責任。然而，筆者認為，無論是學說提及的信賴原則、支配理論、法益開放和閉鎖關係理論或是管轄理論，都無法有效地說明實質根據，也就是「為何」要處罰漠不關心的行為人，因此提出雙重歸責基礎理論，企圖較妥適地調合存有和規範。在此脈絡之下，必須先確立作為犯和不作為犯的相同之處和不同之處，首先，二者之相同處在於對於因果流程均應有實際上的支配，故此係第一步的判斷；不同處則在於，在自由法秩序下，人們無法自我掌控風險時，刑法才必須積極地加以介入來非難行為人，而此包括了補助性體制的建立和風險的事實上承擔，唯有符合這二者要求之行為人，方得以刑法第15條不作為犯加以非難。

* 投稿日：2016年11月15日；接受刊登日：2018年6月6日。〔責任校對：鄭雅文〕。

本文中幅修改自科技部補助研究計畫（105-2815-c-305-012-H）之研究成果。本文作者由衷感謝三名匿名審查人惠賜諸多寶貴意見，使作者能夠重新反思文中論證不足之處，惟文責當由本人自負。

** 國立政治大學法律學研究所刑事法學組研究生。

穩定網址：<http://publication.iias.sinica.edu.tw/02920181.pdf>。



關鍵詞：不作為犯、保證人地位、支配、自我負責、社會連帶、危險前行為。

目次

壹、導論	一、回到原點：由作為和不作為的區別出發
貳、保證人地位的法理基礎探尋	二、不作為和作為的差異析論
一、保證人地位於德國歷史脈絡之演進	三、保證人地位的實質根據——雙重歸責基礎的提出
二、保證人地位實質法理根據——既有學說的看法	肆、結論
參、本文對保證人地位法理基礎的建構	

壹、導論

本文討論不作為犯保證人地位（*Garantenstellung*）實質根據的問題。刑法第15條的不純正不作為犯的保證人地位，其存在基礎究竟為何？一直以來，學者內部意見相當分歧。就我國學者而言，通說繼受德國Armin Kaufmann的功能理論，將保證人地位分為「監督型保證人地位」（*Überwachungsgarantenstellung*）和「保護型保證人地位」（*Beschützergarantenstellung*）二大類型¹；而黃榮堅教授認為刑法第15條第2項的「危險前行為」（*Ingerenz*）係保證人地位的唯一法理基礎，而透過危險前行為的概念來檢驗或詮釋保護型保證人地位和監督型保證人地位的存在正當性²。

1 通說意見參見林山田，刑法通論（下），10版，頁249以下（2008年）；林鈺雄，新刑法總則，3版，頁536以下（2011年）。

2 參見黃榮堅，基礎刑法學（下），4版，頁721以下（2012年）（以下簡稱：黃榮

相較於學者認為危險前行為為唯一的合法性基礎，我國學者如許玉秀教授明白採取「反危險前行為理論」(Antiingerenztheorie)³，許教授於三篇文章中，質疑黃榮堅教授和部分實務見解將「危險前行為」作為保證人地位的唯一理由，申言之，倘若我們肯認了危險前行為這種保證人地位類型，行為人的行為造成他人法益遭侵害，卻沒有直接地得到一個處罰，而是「擬制」成法益遭受二次侵害，而給予行為人雙重處罰，此無疑是過度制裁，倘肯定了刑罰應罰性(Strafwürdigkeit)無法證明的制裁，便有違憲之虞，而我國立法者未經慎思明辨，卻將危險前行為所生之保證人地位明定於刑法第15條第2項，應予以合憲性的質疑；許玉秀教授接著並試圖以「法益開放和閉鎖關係」建構保證人地位的存在基礎⁴。另外，近年來，周滌沂教授則以「自由法秩序之補充性扶助體制」和「風險管轄合意移轉」重新地建構保證人地位的法理基礎，並且於理論建構後，明白地反對危險前行為的保證人類型，氏以風險負責的想法，認為在危險前行為的情形，是行為人為了實現自己自由而創造他人法益風險，此時我們將風險實現歸責給行為人，追究其「作為犯」責任，便為已足⁵。

在德國刑法學界的部分，保證人地位的討論，更是五花八門，令人目不暇給，對保證人地位類型區分居功厥偉的Armin Kaufmann，

堅，基礎刑法學（下）；黃榮堅，論保證人地位，收於：刑罰的極限，頁35以下（2000年）；林東茂教授以罪刑法定原則出發，認為只有危險前行為符合構成要件明確性，參見林東茂，刑法綜覽，7版，頁1-176（2012年）。

3 參見許玉秀，最高法院七十八年台上字第三六九三號判決的再檢討——前行為的保證人地位與客觀歸責理論初探，收於：主觀與客觀之間，頁293-302（1997年）（以下簡稱：許玉秀，前行為的保證人地位與客觀歸責理論初探）；許玉秀，前行為保證人類型的生存權？——與結果加重犯的比較，收於：主觀與客觀之間，頁379-441（1997年）（以下簡稱：許玉秀，前行為保證人類型的生存權？）；許玉秀，保證人地位的法理基礎，收於：刑法的問題與對策，2版，頁65-120（2000年）（以下簡稱：許玉秀，保證人地位的法理基礎）。

4 許玉秀，保證人地位的法理基礎（註3），頁113-120。

5 參見周滌沂，重新建構刑法上保證人地位的法理基礎，臺大法學論叢，43卷1期，頁209-269（2014年）。

將保證人地位分為今日通說所採的「監督型保證人地位」和「保護型保證人地位」後⁶，保證人地位法理基礎的爭論，似乎永無寧日，其中大致上可以分為Bernd Schünemann的「對造成結果之原因具支配力」(Herrschaft über den Grund des Erfolges)理論⁷、Hans-Joachim Rudolphi的中心人物(Zentralgestalt)理論⁸、Ernst Amadeus Wolff和Jürgen Welp等人提出的信賴原則(Vertrauensprinzip)⁹、Harro Otto和Joerg Brammsen的行為期待理論(Verhaltenserwartungsprinzip)¹⁰和立基於規範論的Günther Jakobs提出的組織領域(Organisationskreis)理論¹¹等等，呈現百家爭鳴的現象，由於我國刑法受德國刑法釋義學影響頗深，故德國學術界對於不作為犯法理的討論，對於我國刑法學界思考的廣度與深度，應有相當程度的貢獻。

⁶ Vgl. Armin Kaufmann, Die Dogmatik der Unterlassungsdelikte, 2. Aufl., 1988, S. 283 f.

⁷ Vgl. Bernd Schünemann, Grund und Grenzen der unechten Unterlassungsdelikte, 1971, S. 236-237 (以下簡稱：Schünemann, Grund und Grenzen); Bernd Schünemann, Die Unterlassungsdelikte und die strafrechtliche Verantwortlichkeit für Unterlassungen, ZStW 96 (1984), S. 287 (293 f.) (以下簡稱：Schünemann, Die Unterlassungsdelikte); Bernd Schünemann著，陳志輝譯，德國不作為犯法理的現況，收於：許玉秀、陳志輝編，不疑不惑獻身法與正義——許迺曼教授刑事法論文選輯，頁656-668（2006年）。關於Schünemann教授理論的詳盡介紹vgl. Claus Roxin, Strafrecht Allgemeiner Teil, Bd. II: Besondere Erscheinungsformen der Straftat, 2003, § 32 Rn. 17 ff.; 中文文獻見陳志輝，刑法保證人地位法理根據之分析，收於：公益信託東吳法學基金編，不作為犯的現況與難題，頁319-350（2015年）；周漾沂（註5），頁213-217。

⁸ Vgl. Hans-Joachim Rudolphi, in: Wolter (Hrsg.), Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, 7. Aufl., 2007, § 13 Rn. 21, 27 ff.; 也參見Joerg Brammsen, Die Entstehungsvoraussetzungen der Garantenpflichten, 1986, S. 291 ff.

⁹ Vgl. Ernst Amadeus Wolff, Kausalität von Tun und Unterlassen, 1965, S. 37-38; Jürgen Welp, Vorgegangenes Tun als Grundlage einer Handlungsäquivalenz der Unterlassung, 1968, S. 178 ff.

¹⁰ Vgl. Harro Otto, Grundkurs Strafrecht: Allgemeine Strafrechtslehre, 7. Aufl., 2004, § 9 Rn. 32; Brammsen (Fn. 8), S. 117 ff.

¹¹ Jakobs將保證人地位依據分為對事物的組織管轄(Organisationszuständigkeit)和對人的體制管轄(institutionelle Zuständigkeit)，vgl. Günther Jakobs, Strafrecht Allgemeiner Teil, 2. Aufl., 1993, § 28 Rn. 14 ff.

本文的核心任務，係試圖尋找不純正不作為犯保證人地位之法理基礎，當然免不了將會對既有學說作一檢討。首先我們從上面概述略可窺知，我國學者和德國學者大致上對保證人地位之法理依據，有「功能理論」、「閉鎖理論」、「危險前行為理論」、「支配理論」、「信賴理論」、「期待理論」和「風險管轄理論」等思考方向，本文的任務即在於，尋覓適合於自由法秩序下存續的保證人理論，蓋刑法往往是最後手段，如何不過度干涉人們的行為自由，乃刑法釋義學的亟待克服的難題。另外，危險前行為是否值得被刑法非難，也是我們在做完上述理論之價值取捨或另闢蹊徑後，必須誠實面對的課題。

綜上所述，本文首先擬對於國內外學者所提出的保證人地位法理基礎作一完整的呈現，於此部分，本文除了擇取重要學說類型作出整理分析外，更重要的是藉由設例說明、刑法基礎學理的探尋和筆者所持的自由法秩序的角度切入，試圖說明各種學說的優點與瑕疵；其次，本文將於百家爭鳴的學界意見中，試圖找尋並進一步建構出一條能夠於當代自由法秩序下存續的保證人道路，筆者始終認為，在刑法的最後手段性（*ultima ratio*）下，不應恣意地對行為人做出刑法上不作為犯之評價，除非背後有一套完整的理論證立，否則無疑地係對人們行為自由的過度干預。最後，在對保證人地位實質根據建構出一套體系後，本文將運用該理論檢驗通說和實務承認的保證人類型，試圖限縮過度浮濫的不作為犯的成罪可能；最後，則是綜整研究的結果做成。

貳、保證人地位的法理基礎探尋

一、保證人地位於德國歷史脈絡之演進

(一) 19世紀至20世紀中葉的學說看法

德國學術界開始檢討不純正不作為犯的保證人地位，始於19世紀的Paul Johann Anselm Feuerbach¹²，一直到1938年Johannes Nagler提倡保證人說（又稱為等價說）足足將近一世紀的時間，學者之間對不純正不作為之「刑事責任」有著「違法性說」（法律義務說）和「因果關係說」的激烈對立。前者中又可以細分為「形式法律義務說」和「實質法律義務說」。形式法律義務說（formelle Rechtspflichtlehre）係由Feuerbach所提出，認為保證人地位的來源主要来自（一）法律（二）契約¹³（在之後因果關係理論蔚為通說時，還另加上先行行為），然而，Feuerbach提倡形式法律義務說時未受到重視，一直要到19世紀末葉，Franz von Liszt重新加以提倡，方才蔚為通說至20世紀中葉（至Nagler為止）¹⁴；相對於形式法律義務說，Johannes Franz Wilhelm Sauer、Diethelm Kissin和納粹時期基爾學派（Kieler Schule）的代表人物Georg Dahm和Friedrich Schaffstein則提出「實質法律義務說」（materielle Rechtspflichtlehre）¹⁵，實質法律義務說的提出，和當時盛行的刑法實質

12 Vgl. Hans-Heinrich Jescheck/Thomas Weigend, Lehrbuch des Strafrechts: Allgemeiner Teil, 5. Aufl., 1996, S. 600; Roxin (Fn. 7), § 32 Rn. 3.

13 Vgl. Wolfgang Wohlers/Karsten Gaede, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen (Hrsg.), Nomos Kommentar zum Strafgesetzbuch, 4. Aufl., 2013, § 13 Rn. 30; Jescheck/Weigend (Fn. 12), S. 621; Roxin (Fn. 7), § 32 Rn. 3; 中文文獻請參考許玉秀，論西德刑法上保證人地位之實質化運動，收於：主觀與客觀之間，頁333（1997年）；陳志輝（註7），頁293。國內迄今仍然有學者採取形式法律義務說者，參見余振華，刑法總論，頁200（2011年）。

14 許玉秀（註13），頁333。

15 Vgl. Wohlers/Gaede (Fn. 13), § 13 Rn. 30; Kaufmann (Fn. 6), S. 247-248; Brammsen (Fn. 8), S. 51; Welp (Fn. 9), S. 66-70; 許玉秀（註13），頁345-353。

違法性說（materielle Rechtswidrigkeitstheorie）有所關聯，此說主要訴諸道德觀（公平正義）和整體考察觀點，先有Sauer、Kissin的「對國家及其成員利多於弊」的實質不法概念，到Dahm和Schaffstein提出的「整體考察觀點」，以「健全的國民情感」作為不純正不作為犯中作為義務之根據¹⁶。

相較於「違法性說」，19世紀中葉至末葉盛行的學說係「因果關係說」或稱「因果力說」（Theorie der Kausalität，早在1828年德國學者Stübel即指出先行行為是作為義務的一種類型¹⁷，有先行行為者，必須防止因此造成的結果發生，然而，Christoph Carl Stübel並未進一步闡釋這種作為義務的依據，文獻上大多將其理解成「惡惡相循」，質言之，前面的作為是一種惡行，後續接踵而至的不作為也是一種惡¹⁸。Stübel這種訴諸於習慣法思想的自然循環因果律，被之後的Heinrich Luden進一步加以發揮，引為不純正不作為犯的可罰性依據，Luden認為，法律義務說認為以法律規定、契約之間的約定可以推導出作為義務，是毫無根據的¹⁹，而先行行為反而能夠充分表彰其係適格的作為義務，蓋不作為是否和作為具有等價性，端視該不作為對結果發生是否有「原因力」、「因果力」而定，在此一前提之下，法律及契約而生之關係與結果之間並無因果力，反而是先行行為乃因果鏈上不可或缺之一環²⁰。Luden奠基了因果關係說之通說地位後，繼又有Jodocus Donatus Hubertus Temme、Martin Krug、Julius Glaser、Adolf Merkel等學者於因果力說

16 由於此處涉及的是「不作為犯如何會和作為犯等價？」，白話一點說，即是具有「形式法律義務」、「實質法律義務」或下述之「因果力」之人「能夠」成為刑法處罰、非難的對象，但是這些學說都沒有很清楚地指出這些人「何以」成為保證人（當然，Dahm和Schaffstein的理論有為之後的信賴或社會期待性理論鋪路的影子），而後者才是本文擬處理之核心問題。

17 Welp (Fn. 9), S. 29; Roxin (Fn. 7), § 32 Rn. 3; 許玉秀（註13），頁402-403。

18 Welp (Fn. 9), S. 16.

19 Welp (Fn. 9), S. 30.

20 車浩，保證人地位的實質根據，收於：公益信託東吳法學基金編，不作為犯的現況與難題，頁207以下（2015年）。

基礎上發展先行行為理論（危險前行為說）（Ingerenz-Theorie）和 Maximilian von Buri、Karl Binding 之干涉理論（Interferenz-Theorie）等²¹。

國內學者許玉秀教授指出，「在不純正不作為犯可罰性理論史上，因果關係理論雖然從本世紀初（按：20世紀初）就被違法性理論所取代，但前行為義務類型的法理基礎，仍然停留在因果理論上面」²²，許教授此批評係針對危險前行為作為保證人地位之基礎而來，本文認為精確一點分析，此處應該可以分為二個層面討論：第一為不作為和作為刑事責任上「為何等價」；第二是作為義務之基礎與根據，這二者應予以截然劃分。前者意義上的「因果關係說」係19世紀中葉至20世紀初葉的通說，討論的毋寧係不作為和作為之間是否有著相同的原因力；而後一個問題上，在各種保證人類型中，危險前行為的確是背後有著因果關係理論支撐，然而在保證人地位之法理基礎和實質根據上，因果關係理論卻是鮮有被提出討論的，故二層次應予以區分，切莫混淆。

究竟不作為何以等於作為？因果關係理論和法律義務理論喧騰了將近一個世紀之久，終究於1938年Nagler提倡「保證人說」後始歸於沉寂²³。保證人（Garant）一詞，最早由Binding於1872年提出²⁴，Binding認為„Garant“是不作為者對於第三人之允諾關係，係社會期待不作為者提供一定之協助，以避免危險的產生，故乃不作為犯刑事責任的唯一要素²⁵；Binding之後採行法律因果關係理論（Rechtskausalitätstheorie）的學者Kohler雖然並未使用保證人一詞來

21 Welp (Fn. 9), S. 32, 45 ff.; Jescheck/Weigend (Fn. 12), S. 618; Roxin (Fn. 7), § 31 Rn. 38.

22 許玉秀，前行為保證人類型的生存權？（註3），頁404。

23 Johannes Nagler, Die Problematik der Begehung durch Unterlassung, GS 111 (1938), S. 1 (53 ff.); 中文文獻參見許玉秀（註13），頁332以下的詳盡介紹。

24 Welp (Fn. 9), S. 54; 許玉秀（註13），頁332。

25 Welp (Fn. 9), S. 54.

說明不作為之可罰性，但亦以「置於特定地位」(auf den Posten gestellt)來說明可罰不作為者於社會秩序中的地位²⁶，在此之後，便是Nagler於1938年提出，影響深遠的保證人等價說。

Nagler提出保證人說的目的，主要在於回應上述因果關係說和違法性說的爭論，Nagler理論有別於二者之處，在於氏提出以「保證人地位」說明不作為與作為之間的等價性²⁷，且將其定位於構成要件階層（和違法性說的差異）。Nagler的理論認為，不作為與作為的相同點，在於「構成要件相合致」的「行為等價性」(Handlungsäquivalenz)，倘若不作為與作為表現出相同的意志內容時，就可被稱為「構成要件行為」，進而受到刑法規範相同的評價²⁸。Nagler並認為，法定的構成要件並非表徵行為與結果之間的原因力或因果進程，而毋寧在於該行為表現出行為人之意志²⁹，故和早期的因果關係說也有著重大差異。本文以為，Nagler的貢獻在於，氏在因果關係和違法性說的迷霧中開闢了蹊徑，終結了近百年的紛擾，並且由不作為和作為之結構著手，提出了於「構成要件層次」解決問題的可能性，甚為高明。然而，Nagler只回答了作為犯和不作為犯等價的依據在於「保證人」，並未說明「何人」得以成為保證人，進而在未實施法所期待之義務當下，得以不作為犯加以非難，此須留待二戰後的德國學界加以闡明，也是本文的討論核心³⁰；另外，附帶須指出的是，迄今仍有學界意見認為不作為和作為不可能等價（不作為侵害法益強度不會等同作為），也毋庸等價³¹，不作為犯並不是作為犯的附庸，現實情況下，不作為透過刑法第15條，並且借用刑法分則的構成要件加以非難，僅僅是立法政

26 Welp (Fn. 9), S. 59.

27 Nagler (Fn. 23), S. 59.

28 Nagler (Fn. 23), S. 54.

29 Nagler (Fn. 23), S. 28 ff.

30 車浩（註20），頁205-206。

31 持此見解者如許玉秀，保證人地位的法理基礎（註3），頁110-111。

策上的便宜之計罷了，非謂不作為須和作為等價，我們才能將行為人相繩^{32、33}。

(二) Armin Kaufmann的功能理論

1959年，Armin Kaufmann於„Die Dogmatik der Unterlassungsdelikte“一書中提倡以功能的觀點，對保證人義務做類型化的嘗試³⁴，Armin Kaufmann的嘗試影響往後刑法學界深遠，其理論又被稱為「功能理論」(Funktionlehre)³⁵。功能理論對於保證人類型的分類，分為監督型保證人地位(Überwachungsgarantenstellung)和保護型(保全型)保證人地位(Beschützergarantenstellung)二大類型，迄今通說大致仍沿襲此一分法，前者如頗富爭議的危險前行為、危險源監控；而後者則包含了保護義務承擔(同居的家屬之間互負保護義務)、危險共同團體(如同一登山團體隊員間的相互照料義務)、信賴關係(如：同居人的保護義務)、契約關係及自願承擔保護義務等³⁶。

32 許玉秀，保證人地位的法理基礎(註3)，頁93。

33 許玉秀教授指出，不純正不作為犯適用原本為作為犯設計的犯罪構成要件，完全是立法上的便利使然，蓋倘若於分則一一訂出不純正不作為的構成要件，立法投資過鉅，似乎仍有待克服，參見許玉秀，保證人地位的法理基礎(註3)，頁93-94。另外，國際刑法學會於1984年指出，各國刑法典對於不純正不作為犯應該盡可能地採取分則立法方式，方符構成要件明確性原則，此可參見許玉秀譯，1984年開羅第13次國際刑法會議決議，刑事法雜誌，31卷3期，頁77-79(1987年)。附帶一提的是，關於不純正不作為犯是否有違反罪刑法定原則，此議題相當重要，然而由於篇幅過鉅，僅得另外為文討論，國內學者有採肯定見解者，參見鄭逸哲，構成要件理論與構成要件適用：刑事法學及其方法(二)，2版，頁134-137(2010年)；德國學界的討論，vgl. Matthias Krahl, Tatbestand und Rechtsfolge, 1999, S. 182 ff.

34 Kaufmann (Fn. 6), S. 283 ff.

35 Vgl. Jescheck/Weigend (Fn. 12), S. 621; 許玉秀，前行為保證人類型的生存權？(註3)，頁405；許玉秀，保證人地位的法理基礎(註3)，頁113以下；陳志輝(註7)，頁293-294。

36 通說的分類可參見林山田(註1)，頁249以下；林鈺雄(註1)，頁536-545；陳志輝(註7)，頁294；高金桂，不作為犯與保證人義務，軍法專刊，58卷5期，頁152-157(2012年)。

Armin Kaufmann的分類的確開風氣之先，且奠定該理論於通說地位，歷久不衰；然而，Hans-Heinrich Jescheck和Jakobs等學者指出，Armin Kaufmann的功能說充其量只是對於保證人地位提出分類，對於為何要替保證人地位做出此種分類（亦即保證人地位之實質根據），功能說未能提出令人信服的法理³⁷。本文認為通說的批判應屬有據，蓋分類的源頭必然須存在著法理依據，沒有依據的分類，如同空中樓閣，應屬未竟全功；然而，正如許玉秀教授於文中指出，Kaufmann的貢獻並無法完全抹煞，蓋倘沒有Kaufmann的功能理論，實質保證人地位亦不會被學界廣為接受（一直到1975年西德刑法才增訂第13條第1項保證人地位的明文迄今）³⁸。

（三）小結

以上（一）（二）說明了自19世紀到20世紀中葉Kaufmann的功能理論，惟本文的任務並非探討保證人地位之實質化運動，故不再深究學說之爭辯及箇中底蘊，然而，上開的歷史脈絡，無疑是探討保證人地位實質根據的背景知識，無論是釐清保證人地位之「分類」與「依據」二層次問題，抑或是後文有關前行為保證人類型的討論，都可從上面的理論窺見端倪，故仍花上一些篇幅予以介紹。以下開始，本文將展開核心議題的檢討——保證人地位的實質根據。

二、保證人地位實質法理根據——既有學說的看法

（一）Wolff、Welp和Blei的信賴原則（Vertrauensprinzip）

1. 學說見解

自1938年Nagler提倡的「保證人等價說」和1959年Armin

³⁷ Vgl. Jescheck/Weigend (Fn. 12), S. 621; Hans-Heinrich Jescheck, in: Jähnke/Laufhütte/Odersky (Hrsg.), Leipziger Kommentar Strafgesetzbuch, 11. Aufl., 1993, § 13 Rn. 19; Jakobs (Fn. 11), § 29 Rn. 27 Fn. 50.

³⁸ 許玉秀，保證人地位的法理基礎（註3），頁113。

Kaufmann提出功能理論後，德國學界對於保證人地位實質根據之爭論，即絲毫未曾停歇。關於保證人的實質依據，最早被學界提出的是60年代的信賴關係理論（或稱依存關係理論），力主此說的學者為Wolff以及之後的Welp³⁹。本說沿襲30年代基爾學派Dahm和Schaffstein等人的實質法律義務理論和整體考察觀點，具有濃厚的道德主義色彩⁴⁰。

Wolff教授於1965年出版的《作為與不作為之因果關係》（Kausalität von Tun und Unterlassen）一書中提倡以「依存關係」（Abhängigkeitsverhältnis）作為不純正不作為犯保證人地位之基礎⁴¹，Wolff舉孩童生病的例子說明依存關係，氏指出，母親對於孩童的照料並非一種特殊的優惠、優待，而是孩童本來於常態下即應該享有的，母親有救助其孩童的機會、可能卻不予履行，即違反信賴原則⁴²。Wolff接著指出，在自由法秩序下，人們原則上並無所謂的社會連帶義務，然而，不純正不作為犯毋寧是此一原則的例外，在某一特定時點或情境下，行為人與被害者相互之間存有一特殊關係（besonderes Verhältnis），因為倘行為人袖手旁觀，相對人的社會地位因此會惡化，我們即可認為該特殊關係即依存關係，並構成不作為犯之保證人地位⁴³。Wolff於書中並指出，在某些情狀下，人們會信賴他人會對自身處境伸出援手，而非漠然的不予協助，例如雙方訂有契約時，契約的當事人即對於他方產生信賴、依存關係，此時保證人義務即從中而生⁴⁴。

39 Vgl. Wolff (Fn. 9), S. 36 ff.; Welp (Fn. 9), S. 178 ff.; 其他學者的介紹參見Schünemann, Grund und Grenzen (Fn. 7), S. 93-124; Brammsen (Fn. 8), S. 80-92.

40 Vgl. Georg Dahm, Bemerkungen zum Unterlassungsproblem, ZStW 59 (1940), S. 133 (173-174).

41 Wolff (Fn. 9), S. 36-38.

42 Wolff (Fn. 9), S. 36-37; Schünemann, Grund und Grenzen (Fn. 7), S. 95 f.

43 Wolff (Fn. 9), S. 37-38; 中文文獻參見周漾沂（註5），頁218。

44 Wolff (Fn. 9), S. 40; Schünemann, Grund und Grenzen (Fn. 7), S. 100.

另外，以存有論（本體論）（*Ontologie*）來思考保證人地位的學者Welp，承繼了上述Wolff教授的見解，於《先行行為作為不作為等價性之基礎》（*Vorangegangenes Tun als Grundlage einer Handlungsäquivalenz der Unterlassung*）一書中考察了保證人地位的各种類型（如：危險前行為），而提出以信賴關係（*Vertrauensverhältnis*）作為保證人地位的實質根據⁴⁵，也認為不作為與作為等價的根據正是信賴原則⁴⁶。Welp教授指出，人群之間的依存關係表現為社會內部的和諧⁴⁷，故推衍出倘若有人製造一法所不容許的風險，此時被害人對於危險製造者具有高度的依存性（*Abhängigkeit*），故行為人即具有保證人地位⁴⁸。Welp藉由信賴原則亦肯認前行為為保證人地位的存在。最後，持信賴原則的學者還有德國學者Hermann Blei，Blei於Hellmuth Mayer的祝壽論文集指出，保證人地位的來源是信賴關係，由於行為人事先繼受了某個行為義務，或是行為人事先創設了一個危險、執行了某種業務以致於被害人對該行為人產生了倚賴，這種倚賴即得以作為保證人義務的來源⁴⁹。

信賴原則曾經於1960年代風靡一時，也是當時德國法院面對不作為犯使用最為頻繁的見解，然而於1971年Schünemann的《不純正不作為犯之基礎與界限》（*Grund und Grenzen der unechten Unterlassungsdelikte*）出版後，信賴原則受到了強烈的挑戰與質疑，Schünemann批評Wolff以及Welp、Blei的理論是徹底的倒果為因，不足以正當化保證人地位的根據，國內許玉秀教授亦持相似見解，並曾撰文抨擊，本文於下面將會分析他（她）們的批評意見。

45 Welp (Fn. 9), S. 176; Schünemann, Grund und Grenzen (Fn. 7), S. 104.

46 Welp (Fn. 9), S. 178 ff.

47 Welp (Fn. 9), S. 176; 中文文獻參見許玉秀，保證人地位的法理基礎（註3），頁83。

48 Welp (Fn. 9), S. 179; Schünemann, Grund und Grenzen (Fn. 7), S. 104.

49 Hermann Blei, Garantenpflichtbegründung beim unechten Unterlassen, in: Geerds/Naucke (Hrsg.), Festschrift für Hellmuth Mayer, 1966, S. 119 (140 f.); 中文文獻也請參見許玉秀，保證人地位的法理基礎（註3），頁83-84。

近年來，德國學界關於依賴、倚賴性和保證人地位相聯結的論述，可見Michael Kahlo教授之專論，Kahlo教授指出，家長和小孩之關係，為一原始性之依賴關係，而此依賴性如何和刑法上的保證人相聯結呢？Kahlo教授認為，必須透過立法者制定誡命規範來平衡法主體（Rechtsperson）對其之依賴⁵⁰，白話一點說，孩子對媽媽有依賴性，然而，僅僅一方對他方抱有完全之信任，恐怕會造成一不平等，此時，法律就應該介入、要求媽媽為一定之行為來加以平衡孩子的倚賴。氏進一步建構其對於保證人義務之想法：氏認為，首先必須掌握保證人地位於多大的範圍之內，於各種法主體的共同脈絡（如：家庭、公民社會、國家）下足以發揮作用；而刑法所欲保護之利益（Strafrechtsgut）得以被理解為特定之法主體無法藉由自身之力量來排除危險，又或是基於已然成為穩定之法型態而具外部相互關聯性自由結構（如契約為適例），對與其產生此種關聯之人（Mit-Person）／保證人承擔起一定之責任⁵¹和作為義務，其根本的思想也是在於倚賴⁵²。Kahlo教授進一步說明並歸納保證人地位之類型，除了上開之家庭親子關係、契約等，氏亦承認前行為類型的保證人地位，蓋二人之間也形成了依定的依存關係⁵³。然而，Kahlo、以及氏於文章中引用Kurt Seelmann教授之文均指出，此一依存平衡不應遁入美德（Tugendleistungen）的要求，併予說明⁵⁴。

值得注意的是，迄今仍有學者不願完全放棄信賴原則和道德主義的進路，尤其在美德思想濃厚的華人圈內，更是如此。2014年，成功大學舉辦的兩岸刑事法論壇中，來自對岸的車浩教授明白地批

50 Vgl. Michael Kahlo, Die Handlungsform der Unterlassung als Kriminaldelikt, 2001, S. 256 ff.

51 Kahlo教授原文中係ursprüngliche Verantwortung，學者將其翻譯為「原初責任」，參見古承宗，保證人地位之實質準據（與談稿），收於：公益信託東吳法學基金編，不作為犯的現況與難題，頁367（2015年）。

52 Kahlo (Fn. 50), S. 257.

53 Kahlo (Fn. 50), S. 261 ff.

54 Kahlo (Fn. 50), S. 257.

評和反駁Schünemann的支配理論和因果理論等思想，並為信賴理論受到的批評抱屈，文末，氏進而嘗試以一種以「家庭功能為核心」的新功能主義路徑作為重構保證人地位之實質根據。關於車浩教授的新功能主義的思維，本文於此不擬詳述⁵⁵，僅略提及其對於信賴原則批評意見的反駁：車教授認為，批評意見認為，人與人之間的信賴關係的前提和基礎來自「法律規範」，故沒有法規範不可能使得信賴地位成為保證人義務，但是，問題的關鍵恰恰在於，信賴關係的前提和基礎真的是在法律嗎？假如把人單純的看做是根據懲罰激勵而採取行動的動物，恐怕是一種誤解，亦不符合生活的實際經驗，蓋鄰居之間的互相幫忙時常僅僅基於「樸素的道德情感」或「交往習慣」，是以，毋寧應由道德主義的視角理解信任關係⁵⁶；準此，車教授認為，人群之間的信賴和信任乃奠基於道德而非法律，Schünemann教授和許玉秀教授的批評，並沒有打中靶心，是錯誤的批評⁵⁷。

2. 批判見解之分析

德國學者對於信賴原則作為保證人實質根據的批判，最早應為1971年Schünemann教授的資格論文，Schünemann教授指出，信賴原則的存在需要信賴基礎作為支撐，然而，信賴的基礎必須由法律來決定，有了法律上的禁止或誡命要求，被害人對於加害者才具備信賴基礎，而不是如Blei、Wolff或Welp所認為，有了信賴即產生法律上的義務。簡單言之，正確的推論毋寧應是「法律義務→信賴基礎」，而不是「信賴基礎→法律義務」，所以信賴原則論者所犯的是倒果為因的錯誤，其理論並非保證人地位實質基礎的堅強理由⁵⁸，另外，對於Welp承認的先行為保證人地位類型，Schünemann也給

⁵⁵ 關於車浩教授建構保證人地位的論述，見車浩（註20），頁256-292。

⁵⁶ 車浩（註20），頁247-251。

⁵⁷ 車浩（註20），頁250。

⁵⁸ Schünemann, Grund und Grenzen (Fn. 7), S. 251, 344 ff.

予批評⁵⁹，氏認為，根源於19世紀因果論的先行為保證人地位，應該予以放棄。Manfred Maiwald則認為，信賴原則不足以作為適格的保證人基礎，蓋其欠缺一具體明確的標準，事實上，亦沒有人能夠對特定人產生完全的信賴⁶⁰。而Brammsen教授質疑，什麼是信賴？而建立信賴的標準究竟為何？信賴原則的支持者們並未提出一詳細的基準，使得「信賴」一詞留下給人無限寬廣的解釋空間，幾乎是任人型塑⁶¹。另外，Brammsen教授指出，無論是論者提出的信賴原則或期望（Erwartung），這二個詞彙都蘊涵著「預測」的概念（引用Luhmann說法），倘沒有一定的標準，其作為保證人地位都失之空泛，且難以具體化運用於個案中⁶²，信賴或期待原則唯有以「社會地位」來作為輔助性前提⁶³，才可能作為保證人地位的實質基準。由於Brammsen以社會地位來限制期待／信賴之範疇，藉此亦可得知，氏反對先行為保證人地位，蓋危險前行為製造者並不一定具備「特定的社會地位」^{64·65}。

國內學者對於信賴原則的批評，有許玉秀教授和周滢沂教授，許玉秀教授指出，Schünemann對於信賴原則的批評堪稱中肯，「信賴的基礎係法律，沒有規範無從創造信賴，如果沒有法律的保障，

⁵⁹ Schünemann, Grund und Grenzen (Fn. 7), S. 106 ff.

⁶⁰ Manfred Maiwald, Besprechung von H.H. Kühne's Betrug, ZStW 91 (1979), S. 923 (975).

⁶¹ Brammsen (Fn. 8), S. 85.

⁶² Brammsen (Fn. 8), S. 86; 信賴與期待的概念來自德國社會學家Niklas Luhmann，被刑事法學者加以援引，關於Luhmann的意見，vgl. Niklas Luhmann, Rechtssoziologie, 4. Aufl., 2008, S. 40 ff.

⁶³ Brammsen (Fn. 8), S. 90.

⁶⁴ Brammsen (Fn. 8), S. 90, 385 ff.

⁶⁵ 匿名審稿意見指出：「作者可能也必須要注意的是，學理上對於信賴原則的分析是否正確？這裡的信賴談的是心理性意義的信賴？有沒有可能談的是關於全社會運作的信賴呢，例如溝通行動上的信賴？舉例來說，我們到超商購買一罐飲料，為何雙方會願意交付價金與商品呢？除了法律規定之外，是否還存在著何種機制讓我們願意這麼做？」本文認為，Brammsen的說法便體現了這種全社會溝通意義上信賴的進路（角色期待理論），而不是純粹的心理上信賴，也不完全是下列許玉秀教授等學者指涉的規範上信賴。

君子協定所產生的信賴，只能夠產生道德上的拘束力，不可能產生法律上的義務，故信賴原則實是倒果為因，不足以採信」⁶⁶；另外，她也指出，Welp認為信賴原則得以導出被害人對於行為人的倚賴，因而認為前行為保證人類型的形成，乃由於前行為造成被害人易受傷害的狀況，而倚賴前行為行為人救助。因為被害人需要救助，因此行為人即有救助義務，這期間的道理何在？實在難以明白（顯然是一個循環論斷）⁶⁷。另外，周漾沂教授也指出，信賴原則說明保證人地位問題的能力相當有限，蓋信賴如果要有法律上評價的意義，所涉及的不可能僅僅係「事實性信賴」（faktisches Vertrauen），而應該指涉「規範性信賴」（normatives Vertrauen）⁶⁸。周教授和許玉秀教授的論述過程大致一致，而均認為純粹道德上的義務（君子間的協力義務）無法作為法律上保證人義務之來源。另外，縱使他人有長久的照護或協助事實，也不能就此推導出他人即負有保證人義務，故即便該信賴期待幻滅，該幻滅結果也只能歸責於己，而非他人⁶⁹。氏舉出一「老農救助案」作為例子，一位獨居的老人居住於深山，古道熱腸的他時常對陷入危難的登山客提供即時性的援助，導致很多登山客因而減少自救設備，一日老農卻反於常態而不予救助，此時我們能否以不作為殺人罪對老農加以苛責？答案顯然是否定的，蓋老農一開始即無所謂的救助義務，故一長期的倚賴事實，也不能反證其具有保證人地位⁷⁰。結論是：所謂信賴或依賴關係，乃表徵保證人地位之規範性關係的反射結果，而不會是決定理由⁷¹。

66 許玉秀，保證人地位的法理基礎（註3），頁84。

67 許玉秀，前行為保證人類型的生存權？（註3），頁414。

68 周漾沂（註5），頁219-220。

69 周漾沂（註5），頁219。

70 周漾沂（註5），頁219-220。

71 周漾沂（註5），頁220；同此結論：陳志輝（註7），頁300。

3. 本文見解

本文認為，信賴原則是不能夠充分說明保證人地位實質根據的，但本文亦不完全贊同Schünemann和許玉秀教授的批評意見，Schünemann和許玉秀教授認為唯有規範能夠導出義務，來對信賴原則加以撻伐，就這一點而言，本身即存在相當的疑問，以一個仍須待證的前提來反駁信賴原則，本文認為不具有說服力。筆者認為，誠然，保證人地位實質根據的型塑，道德色彩的影響雖然應盡可能地降低，也必須嚴格區分法律義務和德行義務（Tugendpflicht），但批評意見認為人群之間的信任應該由法律來建立，是不無疑義的。試舉一例如下：X小姐因為公司業務需要，派其前往金門出差，X於出門前將3個月大的女兒託付給鄰居Y照顧，並且表示2天後將會返家，詎料霧鎖金門導致飛機無法起降，Y仍然替X照顧其女兒，X也深信Y會如此做。我們此時不免追問：X深信Y會如此做的理由在哪？此一信賴的來源難道會建立在反對意見所云的「法律」之上嗎？顯然在許多情況下，並非如此，故Schünemann和許玉秀等教授的此點批評意見不足採信，而且他（她）們也沒有明白地說明，何以規範即可導出信賴。從法律社會學的觀點而言，相當一部分的規範並沒有發揮任何作用，即可反駁此一論點。

本文認為，正確對信賴原則或倚賴原則的批評毋寧在於下列論點：無論是何種類型的信賴，指涉的均僅為實然面的層次，而現在要證立的恰好為應然面、也就是「為何信賴得以導出法律義務」的問題，信賴原則的論者並沒有清楚告訴我們此一層次的問題，甚至也無法告訴我們問題的解答。申言之，本文認為，論者僅僅討論「道德效力」或是「規範效力」，而沒有觸及到保證人地位實質核心問題——「規範正當性」的議題，故並不能夠算是成功的討論，反而落入「以實然擷取應然」的困境。我們不能憑著一己的想像甚至是虛妄，而強制他人接受自己的信賴，尤其在已經涉及到刑法上義務時，這種強制壓縮他人行為自由而保護自己利益的行為，倘若沒

有實質規範上的正當性，那麼便是一種強制性的連帶，且是不附任何理由的恣意連帶。

另外，信賴原則雖然較功能理論多出一事實上的表徵，而擬以「信賴」作為保證人地位的實質根據，相比於功能理論更邁進一步，然而若進一步追問信賴從何而來，免不了仍然會得出諸如「信賴狀態乃由規範所保護」或是「信賴狀態乃共同體對於規範的社會共識」等論述，形成一種高度的循環論證，最終免不了仍須一定的社會事實基礎才能夠說明信賴⁷²。又如學者所言，縱無法憑藉被害人主觀上一己的事實上信賴而導出刑法規範上的義務，惟倘信賴指涉的是規範性的信賴，那麼就必須回答為何社會規範得以推導出信賴的共識⁷³，而信賴原則支持者並無說明此點，可謂功敗垂成。

最後是次要的論證，本文和許多論者均認為，信賴或倚賴原則欠缺具體明確性，導致法律適用者的恣意風險增至最大，正如同上開Brammsen正確的指出，究竟是什麼樣的信賴，方足以成為適格的保證人地位，無論是Welp的社會和諧關係破滅理論，抑或是Blei的繼受義務理論，都沒有將信賴的範圍劃定清楚。準此，本文以為，倘若僅僅由Luhmann社會學對於期待或信賴的概念即欲非難一個不作為行為人，那麼對於人們自由領域的戕害，無疑是顯而易見的。

（二）Schünemann「對結果發生的重要原因有支配」理論

1. Schünemann 的企圖心——擴大支配理論作為「不作為犯」與「作為犯」的對等原則

關於保證人地位實質根據的討論，德國學者Schünemann的支配思想，可說是極其重要、卻也頗富爭議的理論⁷⁴。Schünemann在

⁷² Wohlers/Gaede (Fn. 13), § 13 Rn. 34.

⁷³ 周漾沂（註5），頁220。

⁷⁴ Schünemann, Die Unterlassungsdelikte (Fn. 7), S. 293 f.; Bernd Schünemann著，陳志輝譯（註7），頁656-668（2006年）。

1971年哥廷根大學的博士論文中，發展「對結果發生的原因具支配力」作為貫穿作為犯以及不純正不作為犯的對等原則，企圖將支配的概念統一正犯，成為「一元的正犯概念」⁷⁵。由於Schünemann的支配理論涉及到他的整體正犯概念以及該概念的基礎——Roxin的犯罪支配理論，所以本文必須先對於理論背景作一扼要的介紹。

Roxin教授於1963年於其教授資格論文《正犯與犯罪支配》(Täterschaft und Tatherrschaft)中，提出犯罪支配理論，並對其有完整且具開創性的論述。Roxin根據存在論和目的論的綜合考察模式，認為正犯是「行為事實的核心人物」(Zentralgestalt des handlungsmäßigen Geschehens)，這是正犯的本質，可以做為先於法律的區分標準，亦可以擔當正犯與共犯之間的區分標準⁷⁶。從正犯是「行為事實的核心人物」的大前提出發，Roxin認為只有具體行為過程的核心人物才能被稱為「犯罪的主宰」(Tatherr)，而犯罪支配的概念即是為了具體化該概念而誕生⁷⁷。在此之上，Roxin將支配分為行為支配(Handlungsherrschaft)、意思支配(Willensherrschaft)和功能支配(funktionelle Tatherrschaft)，俾能類型化各種正犯概念，而其中的行為支配概念，即是「單獨直接正犯」的特徵。另外，Roxin發現到，有一種特殊犯罪類型，是無法劃歸在犯罪支

75 Vgl. Schünemann, Grund und Grenzen (Fn. 7), S. 236 f.; Bernd Schünemann, in: Jähne/Laufhütte/Odersky (Hrsg.), Leipziger Kommentar Strafgesetzbuch, 11. Aufl., 1993, § 14 Rn. 17 (以下簡稱：Schünemann, LK¹¹); Wohlers/Gaede (Fn. 13), § 13 Rn. 3; Roxin (Fn. 7), § 32 Rn. 23 f. (Roxin認為Schünemann的支配理論最足以說明不純正不作為犯的保證人地位根據，惟Roxin和Schünemann建構正犯之理路仍有差異，詳見後述)；中文文獻參見許玉秀，實質的正犯概念，收於：刑法的問題與對策，2版，頁51（2000年）；陳志輝，身分犯之正犯的認定——以德國義務犯理論為中心，政大法學評論，130期，頁390-391（2012年）（以下簡稱：陳志輝，身分犯之正犯的認定）；陳志輝（註7），頁319-320；周漾沂（註5），頁213。

76 Claus Roxin, Täterschaft und Tatherrschaft, 8. Aufl., 2006, S. 25.

77 Roxin (Fn. 76), S. 108.

配理論之下的，那就是所謂的「義務犯」⁷⁸，在刑法上，有些犯罪類型並無法透過犯罪支配理論加以確定「正犯」究竟是誰，例如德國刑法第343條之脅迫取供罪，其犯罪主體必須為公務員，普通人脅迫被害人雖然具有前述正犯表徵的意思支配，然卻不會成立正犯⁷⁹。這種犯罪類型通常我們稱之為「身分犯」⁸⁰，然而，Roxin認為，比身分犯更適切的稱呼毋寧應是「義務犯」，蓋這些身分之人通常負有刑法以外之義務（如：業務身分犯負有從具體生活中所推導、衍生的特殊義務）⁸¹。總而言之，義務犯是Roxin之犯罪支配理論中的一個異數（和親手犯），無法被涵蓋於該理論之下，故Roxin的正犯概念係「多元的正犯概念」。

不同於其指導教授Roxin，Schünemann嘗試以「對結果的原因具支配力」之實際支配（aktuelle Herrschaft）作為上位原則，而企圖統一正犯概念。不若Roxin將身分犯理解成義務犯，Schünemann認為比義務犯貼切的應是「保證人身分犯」（Garantensonderdelikte）⁸²。申言之，無論是在不作為犯或是身分犯的領域中，Schünemann認為正犯的判斷標準始終圍繞在行為人是否具備保證人地位，也就是對結果發生的重要原因⁸³或對他人無助的法益狀態有支配（Herrschaft

78 Claus Roxin, in: Jähne/Laufhütte/Odersky (Hrsg.), Leipziger Kommentar Strafgesetzbuch, 11. Aufl., 1993, § 25 Rn. 36 f.; Roxin (Fn. 76), S. 352 ff.; 國內文獻介紹Roxin義務犯概念者，參見陳志輝，義務犯，月旦法學教室，23期，頁34-38（2004年）；陳志輝，身分犯之正犯的認定（註75），頁345-380。

79 Roxin (Fn. 78), § 25 Rn. 37; Roxin (Fn. 76), S. 353.

80 僅參見陳子平，刑法總論（上），頁88-89（2005年）。

81 Vgl. Claus Roxin, Strafrecht Allgemeiner Teil, Bd. I: Grundlagen. Der Aufbau der Verbrechenslehre, 4. Aufl., 2006, § 10 Rn. 128; 然而，依照國內學者之觀察，Roxin近年來對於義務犯之「義務」是否僅僅指涉刑法以外之義務，也不免有所懷疑，並似有修正之見解，此可參見陳志輝（註75），頁348-349。

82 參見Bernd Schünemann於中德西刑法研討會中發言，收於：政大法學評論，50期，頁195、416（1994年）；Schünemann (Fn. 75), § 14 Rn. 17；國內文獻參見許玉秀（註75），頁54；陳志輝（註7），頁322；陳志輝，身分犯之正犯的認定（註75），頁391-393。

83 Vgl. Schünemann, Grund und Grenzen (Fn. 7), S. 294 (323 ff.).

über die konstitutionelle Hilflosigkeit)⁸⁴，而倡導所謂的「一元的正犯概念」。Schünemann指出，在身分犯的範疇中，Roxin提出的刑法以外之特別義務並非構成要件之前提，毋寧將其視為一種「附帶的現象」較為妥適⁸⁵，真正構成身分犯之「行為人資格」的應該是保證人地位。在萊比錫註釋書中氏舉例說明之：如德國刑法第266條第2款的背信罪構成要件並不需要違反民法上的義務為前提，而僅僅須具有「事實上之忠誠關係」(tatsächliches Treuverhältnis)即可說明背信罪正犯之資格，Schünemann進而指出，該款背信之構成要件可用「因被害者信賴而對其無助狀態有支配」之保證人地位來加以詮釋⁸⁶；而Roxin於同本註釋書⁸⁷所引之例(德國刑法第203條第1款的洩漏業務機密罪)，Schünemann同樣地認為可以保證人身分犯處理，蓋洩漏業務機密罪之行為主體，除了醫師之外，也可能是協助醫師之人或醫生死後輾轉得知之人，這些人，依Schünemann之見，均係「對法益客體無助狀態有所支配」之人所為之傑作⁸⁸。

準以此言，我們可以見到，Schünemann的「對結果發生的原因有支配」(最上位概念)嘗試將Roxin提倡之犯罪支配擴充至本不屬犯罪支配下位類型的義務犯，並將德國刑法第13條第1項的不純正不作為犯和身分犯(可能係作為犯，亦有可能是不作為犯)，均劃歸於「保證人身分犯」之下，這即是本文於章首所說之Schünemann的企圖。

2. Schünemann 的支配概念——事實上的支配以及事前的支配

Schünemann教授的「對結果的原因有支配」理論，本文認為可簡單歸納出幾個要點：首先，Schünemann於文章中指出，即便德國

⁸⁴ Schünemann, Grund und Grenzen (Fn. 7), S. 342 ff.

⁸⁵ Bernd Schünemann發言(註82)，頁416。

⁸⁶ Vgl. Schünemann, LK¹¹ (Fn. 75), § 14 Rn. 17.

⁸⁷ Vgl. Roxin (Fn. 78), § 25 Rn. 37.

⁸⁸ Schünemann, LK¹¹ (Fn. 75), § 14 Rn. 17.

刑法第13條第1項沒有額外加上「不作為要對應經由作為所實現之構成要件」此一要件，然而，單獨由不純正不作為和積極作為的對等性即可得出，保證人和結果之間的關係必須是和作為對等的，當然，Schünemann表示，這並不代表二者之結果歸責性必須完全相同，毋寧應是「充分的相似性」⁸⁹，所以，與作為相似或對等之要件是：對於侵害法益（造成結果發生之原因）具有強度上可以相類比之意志力（Willensmacht）⁹⁰。第二，Schünemann強調，他所指涉的支配乃對於事件有著實際上、真實的控制（eine aktuelle Kontrolle über das Geschehen），而不同於批評者所指涉的「支配地位」（亦即具有支配的可能性）⁹¹，另外，Schünemann也指出，所謂的實際上、真實的支配，必須符合現在性和絕對性⁹²，也因此於此脈絡下，他不承認危險前行為類型的保證人地位，蓋行為人製造了一個危險前行為後，對於之後的因果流程操控、掌握已經喪失現在的、現實性的支配，而僅僅剩下所謂的結果防止可能性（Abwendungsmöglichkeit），這種防止之可能僅僅具備潛在性的支配，是無法使該不作為與作為等價的⁹³，第三，Schünemann強調，除了具備實際上的支配力外，支配的時間點必須於因果流程啟動之前，亦就是所謂的「事前的支配」，方足以使作為與不作為等價⁹⁴。

當然，Schünemann以支配理論試圖說明不作為犯的保證人地位，和他背後的哲學思想有所關聯，他指出：「我一開始即於方法論的基礎上建立我的不作為概念，是一種介於依照自然主義（或目的主義模式）純粹存在論化的行動和在Jakobs與其信徒們意義下的

89 Bernd Schünemann著，陳志輝譯（註7），頁656。

90 同前註。

91 Schünemann, Grund und Grenzen (Fn. 7), S. 241, 246 ff.; Bernd Schünemann著，陳志輝譯（註7），頁656。國內文獻參見許玉秀，前行為的保證人地位與客觀歸責理論初探（註3），頁296-297。

92 Schünemann, Grund und Grenzen (Fn. 7), S. 231, 235 ff.

93 Schünemann, Grund und Grenzen (Fn. 7), S. 316.

94 Bernd Schünemann著，陳志輝譯（註7），頁656；車浩（註20），頁222-223。

純粹規範主義之間，嘗試取得一個平衡，根據經驗上可得掌握的實際狀況（事物本質），將構成尋法基點的立法者決定加以具體化，並且尋求符合立法價值判斷的『存在論結構』⁹⁵，這是一種中間路線的想法，既可以避免被新康德主義批評由「實然導出應然」的自然主義思維，亦可以避免Jakobs及其追隨者所犯的謬誤，把歸責的原則完全取決於立法者的處置或基本上內容可被任意填補的系統理論⁹⁶。當然，批評者會針對Schünemann的支配方法論提出強烈的質疑，如輕易地使用「事物本質」（Natur der Sache）而未對於該概念說明清楚，又或是支配一詞毫無規範上意義等，這將在下一部分說明之。

3. 批判見解之分析

Schünemann以支配理論重整河山，試圖以「對結果發生的原因有支配」的上位對等原則統一作為犯與不作為犯的處罰根據，然而，除了其指導教授Roxin教授於2003年出版的刑法總論教科書明白地支持其理論，並且認為以支配理論解釋保證人地位最有說服力外，德國多數學者並不贊同Schünemann的支配理論，甚至嚴厲予以批評者，不計其數。而我國學界部分，雖有學者無條件地支持並一一駁斥反對意見的批評外，許玉秀教授和周滢沂教授分別以不同的視角質疑支配概念作為保證人基礎的合宜性，以下將分別闡述之。

首先是對於Schünemann運用事物本質概念當作其方法論的批評，在介紹學者對於Schünemann運用事物本質的批評前，本文有必要先對於何謂「事物本質」略作說明。依Arthur Kaufmann對於事物本質的說法，他認為「事物本質」是一種正確發現法律的觀點，是一種使規範正義與事物正義調和的中間點，在該觀點當中應然（Sein）和實然（Sollen）交會，它是現實與價值互相聯繫的方法論

95 Bernd Schünemann著，陳志輝譯（註7），頁659；陳志輝（註7），頁325。

96 陳志輝（註7），頁325。

上所在，所以，從事實推論到規範，抑或由規範推論到事實，一直是一種有關「事物本質」的推論；另外，「事物本質」是類推的關鍵，它不僅僅於立法上同時也在法律發現上扮演類推程序的基礎；最後，由事物本質得出的思維，係一種類型學的思維⁹⁷。另外，Karl Larenz也在方法論一書中提及事物本質，他寫道：「事物本質」意謂著「同時是一個存有論與規範論的構成要件：一種於實然意義中所具有的以及於實然中或多或少一直被現實化的應然」⁹⁸。

學說上對於Schünemann運用事物本質來說明支配概念抱持質疑的態度，Otto和其學生Brammsen提出了強烈的批評，Otto指出，Schünemann輕率地使用事物本質的概念⁹⁹，Brammsen則於其教授資格論文進一步為文批評，他指出，關於事物本質的內涵以及適用，Schünemann並未有著清楚的說明，蓋事物本質就好比「催化劑」(Katalysator)，俾調和所謂的應然與實然，然而，「催化劑」本身不能是完全空洞無內容，導致缺乏客觀得以識別的特性¹⁰⁰；Brammsen更對於這種源自於Arthur Kaufmann的法律發現過程給予否定的評價，氏認為，此毋寧是一種帶有不明內涵的現象¹⁰¹，並且認為這種與「事物本質」緊密地相結合的類型學思維是不可理解的¹⁰²。國內周滢沂教授則由近似於Jakobs規範論的視角來批判Schünemann的支配概念，他指出：「保證人地位所涉及的是一個規範性陳述，一個具有拘束力的效力宣稱：保證人有義務採取作為。

97 Vgl. Arthur Kaufmann, Analogie und „Natur der Sache“: Zugleich ein Beitrag zur Lehre vom Typus, 2. Aufl., 1982, S. 44; 中文翻譯本參見Arthur Kaufmann著，吳從周譯、顏厥安審校，類推與「事物本質」——兼論類型理論，頁103-104 (2003年)。

98 Vgl. Karl Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 6. Aufl., 1991, S. 417 ff.; 也可參見Arthur Kaufmann著，吳從周譯、顏厥安審校 (註97)，頁107。

99 Harro Otto, Buchbesprechungen, MschrKrim 1974, S. 125, 轉引自：Brammsen (Fn. 8), S. 70.

100 Vgl. Brammsen (Fn. 8), S. 71.

101 Brammsen (Fn. 8), S. 71.

102 Brammsen (Fn. 8), S. 72.

那麼就支配思想首先可以得出的質疑，就是從實然導出應然的謬誤。這樣的謬誤，即使是在說詞上採取一種所謂『類推』作為犯的方式也無法消弭的」¹⁰³；「支配於觀念上是後於義務，作為判斷是否違反義務的標準。然而，在不純正不作為犯中，由於並不是『沒有支配就沒有破壞義務』，而是『沒有支配就沒有義務』，以致於若仍然運用支配思想，將使得支配概念從作為義務違反要件的層次，跨越到作為義務證立的層次。語言上同一的『支配』，在作為犯與不純正不作為犯的作用完全不相同，究竟要如何基於同一實質理由，而為符合事物本質的類推」¹⁰⁴？

其次，國內許玉秀教授則指出，利用支配來解釋作為義務，恐怕隱藏著謬論，氏於1986年的博士論文中指出，支配思想的根本命題是「有權力者負有義務（責任）」，然而，權力引申出的乃「行動自由」，與義務引申的「行動不自由」剛好是相互矛盾的命題，二個相互矛盾的命題倘若能夠互通，那麼這種推論無疑即是一種謬論（ad absurdum）。支配思想雖然很流行，卻不能掩蓋它「本質上的荒謬」¹⁰⁵，正確的說法應該是「由義務導出義務」¹⁰⁶！

第三，對於Schünemann支配理論的質疑涉及到的是由「積極作為犯」的可罰基礎推演出「類似性的規則」（Ähnlichkeitsregeln），Jakobs於教科書中指摘，我們不應該將作為犯複製到不作為犯上，毋寧應該是將作為以及（如同於作為之）不作為予以體系化，而且，實際支配的概念始終僅僅是修正作為犯地被使用¹⁰⁷。另外，Jakobs同時也質疑到，現實支配已經不是作為犯的唯一歸責基礎，

¹⁰³ 周漾沂（註5），頁215。

¹⁰⁴ 周漾沂（註5），頁214-215。

¹⁰⁵ 參見許玉秀，前行為保證人類型的生存權？（註3），頁415。

¹⁰⁶ 參見許玉秀，保證人地位的法理基礎（註3），頁86-87。

¹⁰⁷ Vgl. Jakobs (Fn. 11), § 29 Rn. 28. Fn. 53; 也可參見Bernd Schünemann著，陳志輝譯（註7），頁660；陳志輝（註7），頁332。

例如義務犯（Pflichtdelikte）即一適例¹⁰⁸。另外，Sangenstedt以及Jakobs的學生Timpe指出，即便是在積極的作為中，人對於身體的支配，係被法律所進行的「規範性確立」（normative Festlegung），而不是先於法律的存在論結構¹⁰⁹。而Jakobs的另一位學生Javier Sánchez-Vera則批評，Schünemann舉出的「電影院案」中，於電影院觀看電影的父母對於家中的孩子僅僅具有可能的支配而已，並不具有「現實上的支配」，即便是商品責任的案件也是如此，是以，Sánchez-Vera認為，Schünemann應該於作為犯和不作為犯要求相同程度之支配方屬合理¹¹⁰。

第四，批評者質疑Schünemann支配理論的不確定性，他們主要指向支配概念的高度可塑性，並認為其有時實際，有時卻又規範¹¹¹。這點也是支配理論最常遇到的批評。第五，Sánchez-Vera指出，Schünemann支配理論不公平對待二種情形：他一方面認為在電影院觀看電影的一對父母對於家中正在睡覺的孩子有支配，另一方面卻又否定商品製造商的回收義務，更進一步的，Sánchez-Vera認為電影院的父母對於其兒女僅具有潛在的支配（potentielle Herrschaft），反倒是商品製造商知悉危險源的程度，明顯不亞於該對父母，如此差別對待，難認合理¹¹²。最後，Schünemann理論的批評者質疑，對於「對於被害人無助狀態具支配力」這個類別無法和作為犯的支配相比較，蓋支配的概念和無助狀態顯然是截然不同

108 Jakobs (Fn. 11), § 29 Rn. 28. Fn. 53; Bernd Schünemann著，陳志輝譯（註7），頁660；陳志輝（註7），頁333。

109 Vgl. Gerhard Timpe, Strafmilderungen des Allgemeinen Teils des StGB und das Doppelverwertungsverbot, 1983, S. 171 ff.; Christof Sangenstedt, Garantenstellung und Garantenpflicht von Amtsträgern, 1989, S. 294 ff.

110 Vgl. Javier Sánchez-Vera, Pflichtdelikt und Beteiligung, 1999, S. 129 f.

111 主要來自Maiwald和Vogel等學者的批評，整理已見Bernd Schünemann著，陳志輝譯（註7），頁661註119所列文獻，國內學者對支配概念欠缺確定性的批判已見，周漾沂（註5），頁215。

112 Vgl. Sánchez-Vera (Fn. 110), S. 129.

的，而且我們也無法認為「對於被害人無助狀態」係造成結果發生的重要原因。例如Herzberg即指出，唯有「對造成結果發生的重要原因」才能夠如Schünemann所言，與作為犯相比較，反之，單純的對於被害人無助狀態有支配，是無法相類比的¹¹³。而支配的概念也相當不適合來詮釋所謂的「無助狀態」¹¹⁴。Joachim Vogel也指出，Hilflosigkeit指涉的毋寧是一種支配本身的評價，而非結果，Vogel更舉出小孩子溺斃案作為例子：氏指出，掉落水井的小孩子的無助狀態僅僅是一種特徵，是無法被支配的，唯有掉落和欠缺協助的事實方能被解釋為造成結果發生的重要原因¹¹⁵。

4. 本文見解

本文認為，Schünemann的對「結果發生原因有支配」理論，無法做為保證人地位的實質根據，但在說明本文之意見前，有必要對上開學者之批評作一檢視，首先是許玉秀教授之質疑，許玉秀教授認為支配理論是由權力引申出義務，恐怕是一哲學上的謬論，故應該由義務衍伸出義務，方屬合理，本文認為，此一命題恐仍有待商榷，以下提出二點筆者的疑惑：首先是日常生活語言的意涵，筆者質疑的是，支配真的是一種權力嗎？例如在危險共同團體的案例，不相識的登山客究竟有什麼高於他人之權力？其次是哲學上的論證，Immanuel Kant在道德底形上學（Die Metaphysik der Sitten）中的經典語句：「無時無刻都要將自己及他人當作目的，不能純粹地將他人當作工具來看待」¹¹⁶，Kant法權理論的基本內涵在於每個人於其享有的自由領域內，禁止侵犯他人的自由領域¹¹⁷；Hegel在其

113 Vgl. Rolf Dietrich Herzberg, Die Unterlassung im Strafrecht und das Garantprinzip, 1972, S. 193 f.

114 Vgl. Joachim Vogel, Norm und Pflicht bei den unechten Unterlassungsdelikten, 1993, S. 352.

115 Vogel (Fn. 114), S. 352-353.

116 Immanuel Kant著，李明輝譯，道德底形上學之基礎，頁51-53（1990年）。

117 Immanuel Kant著，李明輝譯，道德底形上學，頁45（2015年）。

著名的法哲學原理第一章即表明：「作為一個個人（Person），並且將他人當作個人來加以尊重」¹¹⁸，此乃做為法概念的基本命題。由西方哲學的背景可以得知，自由和負責應該是一體二面的，沒有那種毫無後顧之憂的自由。假設今天一名屋主在自家圍牆佈滿了通電的鐵絲網，難道我沒有任何義務去防免玩耍的孩童靠近該鐵網嗎？本文對此抱持質疑的見解，蓋一個社會的基本運作應該是要求「權責相符」、「權責相當」，在他人的權利受到侵害或侵犯之虞之際，個體的自由就必須有相應的限縮，是以，本文認為許教授的見解仍有值得澄清之處。另外，Sánchez-Vera的批評（前述第五點）已經係一過時的批評，因為Schünemann教授於2000年已經改變其先前的見解¹¹⁹，而認為商品製造商對於使用該產品的顧客具有實際的支配。但這也可以得證，支配理論有著相當程度的恣意操控可能性。

本文認為，Schünemann教授以「事物本質」來找尋一種介於存在論和規範論的法之發現，似乎是一種中庸之道，也得以避免Jakobs或其學生提倡規範主義「循環論證」之嫌疑，但是，事物本質本身也是一個不確定且流動的概念，雖然不確定性的質疑並不能完全否定該理論的價值，然而關鍵恰恰在於，倘若沒有其他的判斷基準將模糊性降低，那麼是否得單單以其框架人們的行動自由，便有相當的疑問（更甚者，他們必須回應的是，單憑支配是否就可以建構保證人地位，此如以下質疑）；另外，雖然Schünemann一一回應了批評意見的質疑，認為並非如他們所言，係由實然（刑法規範之本體論）導出應然（歸責）¹²⁰，然而，依本文所見，Schünemann沒有貫徹他的思想，蓋於危險前行為的情形，氏以為，

118 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, *Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse*, 1986, § 34.

119 Bernd Schünemann, *Unternehmenskriminalität*, in: Roxin/Widmaier (Hrsg.), 50 Jahre Bundesgerichtshof, Festgabe aus der Wissenschaft, Bd. IV. Strafrecht, Strafprozeßrecht, 2000, S. 621 (640).

120 參見Bernd Schünemann發言（註82），頁286。

源自先行為的因果進程對於不作為之行為人來說毋寧是過去的因果進程，申言之，Schünemann認為，行為人於從事危險前行為之後，該因果流程就已經逸脫出該行為人之支配領域，行為人因而就對其欠缺「現實性、實際的支配」，故不具有救助義務，在這種思想下，本文認為Schünemann理解的支配是一種純粹的自然主義、存在論的支配¹²¹，故其尋法之想法並未一以貫之，縱然其引用Lothar Kuhlen和Ingeborg Puppe的類型學思維（typologisches Denken）¹²²也無法合理化其矛盾。其二，Schünemann不斷地強調對「結果發生原因有支配」係為了發展作為犯與不作為犯之上位對等原則，而能夠使作為犯與不作為犯等價，然而，正如同本文前面所述，等價問題和不純正不作為犯保證人地位「實質根據」的問題，係二者不同層次的議題，首先我們必須先確定行為人的不作為和作為之間是否等價，才進而去追問哪些人得以成為保證人，方為妥當，然Schünemann之支配理論主要係處理等價性的問題，俾與1963年以降，Roxin於作為犯領域中發展的犯罪支配理論相會師，並沒有直接地回答「為何」該行為人得以成為保證人。正如同有學者正確地評論到：「它（支配理論）既沒有令人信服的回答『哪些人是以及為什麼是保證人』的根據問題，同時又在回答根據問題時，把等價問題扯了進來，混亂了兩者的關係，最終把等價問題也攪黃了」¹²³。

另外，本文認為，Schünemann教授雖然不斷堅持其支配理論是一種事實上的支配關係，而非規範性的支配，和其指導教授Roxin所指涉的支配包含規範性有所區別，且論者也於文中反覆強調這一

121 反之，Roxin的支配理論則帶有規範性色彩，故其承認危險前行為類型的保證人地位（另一位奉支配理論為主臬的Rodolphi也承認危險前行為類型的保證人地位），關於Roxin教授的支配理論與Schünemann的差異，參見陳志輝（註7），頁337-339。

122 Bernd Schünemann著，陳志輝譯（註7），頁659-660註113。

123 參見車浩（註20），頁225。

點¹²⁴，然而，Schünemann教授於2011年3月到北京大學演講中舉的案例¹²⁵，似乎逸脫出現實上的支配，而落入規範性的支配：Schünemann指出「孕婦對無助的胎兒和新生而擁有本質和先天上的支配力，因此無論她通過積極的作為悶死嬰兒還是以不作為的方式任嬰兒死亡，都應該按照故意殺人罪處罰」，這個案例充分表現出規範性的一面，蓋倘若該母親於產後身體極度虛弱，我們還能以該母親具有「本質和先天上的支配力」課予其保證人義務，那麼這不是先於事實觀照的規範性決定，又是什麼？而同樣的道理也於電影院父母一案中表露無遺，縱使論者對此反駁：「問題都在於對Schünemann支配概念的誤解上，氏所稱的控制支配（Kontrollherrschaft）是先前就已經建立的」¹²⁶，然而，這種「先前就已經建立的」的說法替理論合理化也是站不住腳的，蓋先前已經建立的支配根本上已經非事實的支配，而係一規範性的支配，惟後者正是Schünemann所排斥、抗拒的，故如此論證恐有循環論斷之嫌疑。從這一點除了可以窺見支配理論之循環論證外，更可以清楚地展開其不確定性的一面，而非如Schünemann反駁Maiwald、Vogel，認為「類型學的尋法模式雖然會產生語意學上模糊之領域，但這個模糊的領域在具體化過程中遞減」¹²⁷之三言二語得以輕鬆帶過的（上開的商品製造人之回收義務，Schünemann見解之改變可見一斑）。本文以為，法治國家要求法安定性，然而支配理論的提出，在某程度上已經背離了此一思考，這某種層面可以說是出發點、方法論上的問題，該理論的實質內涵，幾乎是言人人殊；更何況，法治國刑法必須要從「犯罪者的大憲章」（die magna charta des Verbrechers）¹²⁸

124 參見陳志輝（註7），頁349-350。

125 案例轉引自：車浩（註20），頁232。

126 陳志輝（註7），頁328-329。

127 Bernd Schünemann著，陳志輝譯（註7），頁661。

128 「犯罪者的大憲章」此名言出自von Liszt，關於此名言之不同解讀和評析分別參見林鈺雄，刑法之運用與解釋（上），月旦法學教室，2期，頁63（2002年）；鄭逸哲（註33），頁43-44註104。

進一步地化作「市民自由的大憲章」，這也是罪刑法定原則的根本內涵，保證人地位的實質化運動，某種層面上已經遊走於罪刑法定之邊緣，而Schünemann擬以一個語意學上模糊的支配概念一統天下，作為保證人地位的唯一根據，無疑有加深此等疑慮之嫌。

最後，本文認為Schünemann的支配理論也無法很清晰地說明對被害人無助狀態具支配力的案例群。試舉一例如下：某甲在前往市郊登山時，發現掉落山溝的某乙，此時四下無人，奄奄一息之某乙能否存活，完全取決於某甲是否救助，甲事實上也得以保全某乙的生命法益，甲卻毫無作為，蓋某乙恰好是某甲的仇人，那麼我們是否可以對某甲論以不作為殺人呢？依循Schünemann的看法，這邊僅僅存在單純的結果避免可能性或支配可能性，故不具備現實上的支配，是以，以「對被害人無助狀態有支配」必須以「現實上的支配」為前提出發，此處應不構成不作為殺人罪。本文質疑的地方恰好在於，以下此一設例，真的沒有現實上的支配而僅為支配可能性嗎？：倘若某甲於深山挖了個大洞而未設任何告示牌，製造一危險前行為，而甲也確信只有某乙會經過該路段，某乙也果真掉落至洞內受傷，依照Schünemann的說法，該侵害事件的來源與對象是甲事前可以支配、控制的，故符合「對被害人無助狀態有支配」，然而，Schünemann的理論架構恰好是反對前行為類型的保證人地位，究竟應如何整點此一矛盾，似仍有待斟酌。

綜上，本文以為，Schünemann的「對結果的原因有支配」的事實、事前支配理論並無足夠的說服力作為保證人地位實質根據，主要原因即出在其方法論的問題，固然，傳統的德國法學方法將尋法模式以「在法規構成要件之規定（規範）與生活事態（事實）間往返來回」¹²⁹，但對於一個可能剝奪他人自由的刑法理論建構，除了恪守該原則之外，更重要的毋寧是處罰的正當性；是以，除非可以

¹²⁹ Vgl. Karl Engisch, Logische Studien zur Gesetzanwendung, 3. Aufl., 1963, S. 15.

說明單具有支配即可構築保證人地位，進而制裁行為人，否則無法消弭其不確定性造成恣意的疑慮。

（三）許玉秀教授之「法益開放和閉鎖關係」

1. 理論介紹

國內許玉秀教授認為，法益的閉鎖和開放關係得以決定保證人地位之法理基礎，氏由保護法益的觀點出發，來探討行為人與法益、侵害法益來源之間，以及行為人與犯罪之人的關係（三種類型），究竟係法益之開放抑或是閉鎖關係¹³⁰，介紹如下：

（1）以開放關係來決定犯罪防止義務

許玉秀教授的法益開放和閉鎖關係，本係奠基於犯罪防止義務之上。她認為，在傳統思想中，犯罪之人通常會被視為一危險源，然而，犯罪人也僅是在犯罪行為時具有危險，平時並不能將其視為易燃之物或爆裂物一般，更何況一個人並無法支配另一人；再者，她指出，對物的管領義務得以移轉，然而並不適用對「犯罪行為人」身上，因此毋寧應獨立觀察犯罪防止義務之基礎，是以，基於救助法益的觀點，必須視義務人與犯罪人間的關係是否有意義而定。而有意義者，亦即該關係是為了保護法益而存在，則會產生犯罪防止義務，反之則否，前者好似對法益開門的關係，故稱「開放關係」，後者則好似對法益關門的關係，故稱為「閉鎖關係」。這個結論提供二個重點：第一，法益係決定義務之要素；第二，即許玉秀教授念茲在茲的，唯有義務方能導出義務，而非由信賴或支配導出義務¹³¹。

¹³⁰ 許玉秀，保證人地位的法理基礎（註3），頁115-119。

¹³¹ 許玉秀，保證人地位的法理基礎（註3），頁115。

在此前提下，許教授逐一檢驗各種社會上之關係：屬於開放關係者，如父母對於子女之關係，蓋父母對於自己的下一代有著教育、防免其為惡之義務（民法第1059、1084條懲戒權規定可以得證），另外屬於開放關係者還有監護關係、國家強制關係（公務員服從關係）、監獄管理員與犯人間的關係和中小學教師對學生的關係。而閉鎖關係則如夫妻關係，因為夫妻關係則是為各自利益而建立的關係，故對於其他法益而言是閉鎖關係，無法產生犯罪防止義務。其他如同居、合夥或老闆與員工之間之關係，都僅能謂閉鎖關係（為彼此私利而組成）¹³²。

（2）以閉鎖關係決定行為人與法益、侵害法益來源之間之義務

許玉秀教授對於犯罪防止義務以外之保證人地位類型，也嘗試用開放和閉鎖關係來去理解，不過要予以注意的是，其和犯罪防止義務恰恰相反，惟有不作為行為人與法益處於閉鎖關係時，才具有防免結果發生之義務。屬於這類型的，包括父母子女、兄弟姊妹¹³³和夫妻關係等，然而，氏也承認，對於這種關係是否會加以擴張或縮小，必須取決於時代價值體系，以實質觀點彈性地來決定保證人地位。另外，因自願承擔義務（如看護、危險共同團體）而生的關係，基本上僅對於其所承擔之義務類型（如看護對身體法益；危險共同團體對他人之生命法益）係閉鎖關係，進而生保證人地位。

當不作為行為人與法益處於開放關係時，原則上並不具有保證人地位，然而，倘此時法益仍然受害的情況下，則必須尋找閉鎖關

¹³² 許玉秀，保證人地位的法理基礎（註3），頁116-117。

¹³³ 關於兄弟姊妹之間是否具有保證人地位（閉鎖關係），許玉秀教授於2002年的一篇文章中指出，兄弟姊妹間的關係是一種被決定之關係，似乎僅能由家庭功能之目的導向（信賴）來說明其保證人之性格，否則依照自願義務承擔毋寧應得到相反的答案，可見其對於兄弟姊妹型似乎仍有所遲疑。參見許玉秀，夫妻間之保證人地位——兼論通姦罪——評釋九十年臺上一五六號、九十年臺上更（一）字第九四號、八十六年度上訴字第三九八六號、八十七年度訴字第一五六五號判決，台灣本土法學雜誌，39期，頁89（2002年）。

係，而此時尋找對象則改成侵害來源與不作為人之間。這類例子如負責監督侵害法益來源之商品製造人，其有排除瑕疵產品不於市面上流通之義務。通說承認的保證人類型的法理基礎，為閉鎖關係（亦即不包含犯罪防止義務之類型）¹³⁴。

2. 本文見解

對於許玉秀教授以開放和閉鎖關係來決定保證人地位之有無，國內學者周漾沂提出其想法：依周教授之見，許玉秀教授之看法包含了一種體制（Institution）的觀點，且該觀點從實質的角度去探尋刑法與刑法外社會關係的整合可能性，頗富參考價值¹³⁵。而Vogel也於文中提及許教授的觀點帶有「涉內與涉外之體制關係」（institutioneninterne und institutionsexterne Beziehung）的味道，可惜的是，氏僅僅簡略帶過，而並未深究¹³⁶。

本文認為，硬是區分開放關係和閉鎖關係，似仍無法一舉解決保證人地位實質根據的問題，更可能由於其標準的模糊終至流於恣意。首先，她並沒有說明，為何只要關係連接對象在於「法益」，刑法即須無條件的介入？如此一來，刑法的最後手段性將蕩然無存。而其於2002年發表之文章中，強烈批判「乳癌救治案」¹³⁷中的更審法院認定夫妻之間並不具有互相保護的保證人地位，完全是一場誤會，且迄今國內外學者都有一致的共識¹³⁸。這段論述恐值得商

¹³⁴ 許玉秀，保證人地位的法理基礎（註3），頁117-119。

¹³⁵ 周漾沂（註5），頁238。

¹³⁶ Vgl. Vogel (Fn. 114), S. 371 Fn. 396.

¹³⁷ 「乳癌救治案」的大概為一已婚的家醫科醫師，瞞著其妻子和小三交往，該妻發現乳房出現硬塊，而丈夫卻因和小三交往惡意隱瞞實情，導致妻子就診時早已回天乏術的案例。此案例引發學者之間對於殺人故意、作為和不作為區分和保證人地位的爭辯，國內文獻對本案有所探討者，參見許玉秀（註133），頁80-92；黃榮堅，基礎刑法學（下）（註2），頁676-677；林東茂（註2），頁1-165；蔡聖偉，作為與不作為的區分（與談稿），收於：公益信託東吳法學基金編，不作為犯的現況與難題，頁117以下（2015年）。

¹³⁸ 許玉秀（註133），頁89。

權，蓋什麼叫作共識？一個多數學者認為已經實質化的保證人類型，為何就可以拘束法律適用者呢？如此一來，恐怕有忽視我國刑法第1條、德國基本法第103條第2項罪刑法定原則中「習慣法非適格的法源」之嫌¹³⁹。本文認為，最高法院及更審法院雖然和多數學說所採的見解有所出入（通說將夫妻列為保證人類型之一），惟此尚不足以認定法院見解即為錯誤，否則恐怕就落入推論過快，而忽略實質論證之嫌疑。

其次，許教授將犯罪防止義務獨立於一般保證人地位類型，認為於犯罪防止義務下，惟有開放關係才得以構成保證人地位，此見解恐怕也值得討論一番，學者有以許玉秀教授對於Armin Kaufmann功能說解讀作為出發點，認為「保護法益類型的保證人地位」和針對「特定人」的法益有關，而「監督危險源的保證人地位」則是針對「每個人」的法益，而「犯罪防止義務」則涉及了「對法益有意義之功能關係」，然而，無論是「監督危險源的保證人地位」和「對法益有意義之功能關係」不都是和「針對每個社會成員的法益」相關嗎？倘若這項質疑成立的話，則「犯罪防止義務」類型的保證人地位就沒有獨立存在的必要，保證人地位的判斷基準就完全取決於閉鎖關係，這樣真的對於保證人地位的實質根據有比較清楚嗎？頗值懷疑¹⁴⁰。本文支持此見解，蓋依據許玉秀教授的脈絡，氏將「犯罪防止義務」獨立出來判斷的目的在於，沒有人可以將他人視為一個潛在的危險源，然而，這樣的說法恐怕失之籠統，固然在人性尊嚴作為法治國家的基本價值下，恣意地將人貼上標籤恐有悖於該信念，然而，無從否認的是，潛在的犯罪者是現代社會下無可迴避的問題，犯罪學家Travis Hirschi承繼了Emile Durkheim的觀點認為，人性中惡的因子係與生俱來的，犯罪係人類的本能，人人都有犯罪傾向，氏甚至認為犯罪學之重點應探討為何人不會犯罪為

139 批評已見鄭逸哲（註33），頁136。

140 陳志輝（註7），頁303-304。

惡¹⁴¹，或許Hirschi的觀點過於激進，但本文以為於現實社會的脈絡下，毋寧以後者之說法較為可採。是以，本文認為似乎並無必要將「犯罪防止義務」獨立於「監督危險源的保證人地位」之外。

再者涉及到該理論本質性的問題，學者指出，必須由刑法的法義務本質來切入思考，來決定支撐該關係是否有正當性，換言之，應該透過一個規範性標準，在眾多目的在於保護法益的關係中篩選出具刑法上適格者¹⁴²，本文支持此一見解，蓋依許教授的說法，原則上區分開放和閉鎖關係的標準在於行為人與法益（來源）的關係，然而，保證人地位實質根據的問題，正好就是我們究竟應該篩選何種法益作為刑法上適格的保護對象，並非發生關係的目的在於保護法益，刑法即需要無條件地加以介入，否則可能會有不設限的保護體制之疑慮，而後者正是本文所拒卻的；再者，開放和閉鎖關係的見解，依照筆者之見，恐怕也只是在功能理論的基礎上，作進一步的分類標準，似乎並未給予我們更為清晰的判斷基準，有淪落為類型化、而非提出實質根據之虞。

綜上所述，本文認為，法益之開放和閉鎖關係並沒有辦法提供保證人地位一個更為清晰的實質根據，故不採之。

（四）Jakobs和Pawlik規範主義下的管轄理論

1. 理論介紹

Jakobs在1983年的第一版刑法總論教科書的前言中表示，在有必要對所有刑法概念進行規範化和功能化的情形之下，作為犯和不作為犯之間的差異已經不再這麼明顯了，因為它們都可以被統合於對事物的組織管轄（Organisationszuständigkeit）和對人的體制管轄

¹⁴¹ 參見李自強，暴力犯罪之社會與環境因素，收於：楊士隆編，暴力犯罪：原因、類型與對策，3版，頁100（2015年）。

¹⁴² 參見周漾沂（註5），頁239。

(institutionelle Zuständigkeit) 之下^{143、144}。而這樣的觀點建立在Jakobs的法哲學觀點，氏認為，人可以型塑(組織)世界，但始終生活在一個被體制塑造的世界裡。是以，穩定的規範期待(normative Erwartung)對於實現社會接觸是必要的，而此穩定的規範期待可以與二種不同的對象範圍發生關係¹⁴⁵。詳言之，在消極的層面，期望所有個體都能審慎地約束自己的組織行為，避免妨害他人和產生外部影響，倘若消極的期望落空了，即是基於「組織管轄」所生的犯罪或是支配犯；而進入與他人共同支配的領域之後，亦即在積極的層面，人們開始對被體制賦予責任的人抱持期待，期望該人可以為自己帶來體制的福祉，倘若這種期望落空，即是基於「體制管轄」的犯罪或是義務犯¹⁴⁶。以下將Jakobs的思路作更清晰的解說：

首先，依照Jakobs教授的見解，無論於作為犯與不作為犯都必須具有保證人地位，而二者都可以被歸納於組織領域(organisationskreis)或組織管轄(Organisationszuständigkeit)的概念底下¹⁴⁷，前者主要應用於客觀歸責(objektive Zurechnung)範疇，例如於棘手的特殊認知(Sonderwissen)¹⁴⁸問題，Jakobs便將其與保證人地位相連結¹⁴⁹；又如信賴原則的應用，Jakobs也將管轄概念運用於其

¹⁴³ Vgl. Günther Jakobs, Strafrecht Allgemeiner Teil, 1983, S. VI.

¹⁴⁴ 但Jakobs於二版教科書，仍然將作為與不作為加以定義，其將作為定義為「個人得以避免結果發生」，而將不作為定義為「個人得以避免的不阻止結果發生」；vgl. Jakobs (Fn. 11), § 6 Rn. 20, 31 f.

¹⁴⁵ Vgl. Jakobs (Fn. 11), § 1 Rn. 7.

¹⁴⁶ Jakobs (Fn. 11), § 1 Rn. 7.

¹⁴⁷ Jakobs (Fn. 11), § 7 Rn. 56.

¹⁴⁸ 關於客觀歸責特殊認知的問題，許玉秀教授即表示此係一芒刺在背的問題，參見許玉秀，走出主觀與客觀的迷思——一個(不(太)不)謙虛的嘗試，收於：主觀與客觀之間，頁32(1997年)。由於和本文主題並非直接相關，故暫不贅述。近年來徹底分析、檢討特別認知並為客觀歸責基本路線辯護者可參考Luis Greco, Das Subjektive an der objektiven Zurechnung: Zum „Problem“ des Sonderwissens, ZStW 117 (2005), S. 519-554.

¹⁴⁹ Jakobs (Fn. 11), § 7 Rn. 49 f.

上。而組織領域係指，為了防免他人受到損害，行為人就有必要耗費精力，因為凡是運用行為自由之人，就必須承擔起精力的耗費¹⁵⁰。在這個前提之下，不僅僅是支配犯會被Jakobs納入組織管轄的範圍，交易往來義務（die Verkehrspflichten）、危險前行為或承擔結果之避免義務都會被納入組織管轄的範疇¹⁵¹，因為它們都基於一個理由：在發展該組織領域時需要替他人著想¹⁵²。而體制管轄或基於義務而生的犯罪則和連帶性（Solidarität）有著密切關係，Jakobs認為，為了維持社會的安定和法益的存續，必須建立某些體制性的義務，而得以期待公民在「某種情形」下犧牲自己，對他人施以協助¹⁵³。而這個「某種情形」，依照Jakobs的說法，必須係該體制對於社會基本構成具有重要性時，我們方能以該公民破壞體制而以不作為犯相繩¹⁵⁴，在他的教科書中，舉出了父母對孩子的關係、婚姻關係、收養和監護、特別的信賴關係以及先天的國家義務（die genuin staatlichen Pflichten），作為建構刑法上適格的體制管轄義務^{155、156}。

150 Jakobs (Fn. 11), § 28 Rn. 14.

151 Jakobs (Fn. 11), § 29 Rn. 29 ff.

152 Jakobs (Fn. 11), § 28 Rn. 14.

153 Jakobs (Fn. 11), § 7 Rn. 70 f.; § 28 Rn. 15; § 29 Rn. 57 f.

154 Jakobs (Fn. 11), § 29 Rn. 58.

155 Jakobs (Fn. 11), § 29 Rn. 59 ff.

156 特別留意的是，Jakobs後期已經將婚姻關係而生的保證人地位予以刪除，原因在於德國實施婚姻改革法，將離婚（德國民法典第1564條以下）的難度大幅度的降低，vgl. Günther Jakobs, Die strafrechtliche Zurechnung von Tun und Unterlassen, 1996, S. 35. 另外，不作為提供的虛偽宣誓的幫助（偽證），在舊式離婚程序的特殊情形：一個訴訟當事人違反真實地否認與第三人（相姦人）通姦，當該第三人（相姦人）作為證人被傳訊時，假使他沒有阻止其虛偽宣誓，將構成不作為犯。由於通姦行為被理解為破壞市民社會（die bürgerliche Welt）體制的行為，原則上它就證立了一個用欺騙來掩飾的犯罪（這在Jakobs的體系下屬於違反組織管轄的危險前行為保證人地位類型）。然而，自從婚姻演變為一個容易解除的契約關係，這一體制管轄權就解除了，有不正當關係的一方便只須對他自己的話語負責。關於此一部分的詳細闡述，vgl. Günther Jakobs, Vorangegangenes Verhalten als Grund eines Unterlassungsdelikts: Das Problem der Ingerenz im Strafrecht, Akademie-Journal

而這二種不同的對象範圍，必須和消極義務（不侵害義務）和積極義務（協助義務）相連結來理解，前者係人們在管轄自由（Organisationsfreiheit）的一個必要的補充，即對向義務¹⁵⁷：一旦確定了某個人對其管轄的領域負責，他就必須保證不發生特定之損害。Jakobs指出，作為一名司機撞了人並導致其身亡，就違反了禁止規範；相對地，如果沒有很好地自我管理，如作為司機沒有轉向或剎車而撞上路人，就是無視於一個誠命規範。他於文中指出，如果不是司機自己，還有誰應當操控手臂、使用方向盤和剎車？該義務的狀態無疑是一種禁止——違反該禁止規範將構成作為犯（一個通過積極行動實施的犯罪）；相對地，其在一定的範圍內也是一種誠命（涉及了在自己的管轄領域中不輸出危險的義務），當處於交往不夠安全的狀態，假使駕駛沒能確保他的管理範圍，就構成了一個不作为犯¹⁵⁸。而後者則是對於市民自由的一種限制（補充），蓋刑法上的期待，不僅僅包括消極的不輸出危險的期待，更於某些情形下，賦予人們對他人建構一正常社會運作的期待，而「體制管轄」和「義務犯」即被Jakobs劃歸到此一招牌下¹⁵⁹。

在理論建構上和Jakobs相近者為Michael Pawlik，Pawlik也以積極義務與消極義務出發，建構其保證人地位的實質根據，Pawlik在多篇文章中強調體制在刑法學上的意義，爾後總結在2012年的„Das Unrecht des Bürgers“一書當中。Pawlik認為保證人地位的實質根據在於一定的「社會經濟的基本組成條件」（infrastrukturellen Rahmenbedingungen）／「確保個人存活的基本現實條件」

2/2002, S. 8 (10)（以下簡稱：Jakobs, Vorangegangenes Verhalten als Grund eines Unterlassungsdelikts）.

¹⁵⁷ Jakobs, Vorangegangenes Verhalten als Grund eines Unterlassungsdelikts (Fn. 156), S. 8.

¹⁵⁸ Jakobs, Vorangegangenes Verhalten als Grund eines Unterlassungsdelikts (Fn. 156), S. 8-9.

¹⁵⁹ Jakobs (Fn. 11), § 1 Rn. 7.

(Gewährleistung grundlegender Realbedingungen personaler Existenz)¹⁶⁰，並且認為德國刑法第323條C不作為救助罪的基礎正好在於公民無法自我負責時，建立一種連帶義務而為他人犧牲，以便在公民孤立無援時能夠建立安全網，這便是體制在於刑法上的意義，俾能真正達到公民自由¹⁶¹。Pawlik接納了Hegel對於公民社會和自由的看法，認為為了達到具體、現實的自由(konkret-realer Freiheitlichkeit)，必須建立一定的連帶義務並課予一定社會角色，以提升公民福祉。具體的實證法規範如德國刑法第153條以下(偽證罪等)、第324條以下環境犯罪和租稅法第370條的稅捐繳納義務¹⁶²，屬於強制性的公民不作為義務，另外，公民對於警察等公務人員有一種特別的依存關係(spezielles Abhängigkeitsverhältnis)，在Pawlik的看法下，也被納為保證人地位的類型之一¹⁶³。Pawlik和Jakobs的出發點如出一轍，認為體制的意義，在對於社會存續有迫切性、根本性的態樣上，法即必須介入人們的自由領域，對自由的行使做出一定的限制，以達成真正的自由。

2. 本文見解

Jakobs和Pawlik的保證人地位理論，反映出濃厚的規範主義思想和哲學社會學的影子，然而，學者對於管轄理論提出了尖銳的質疑，Schünemann教授於1995年的一篇文章中詳細論述Jakobs以及Freund(Freund的教授資格論文中，其觀點和Jakobs相仿)的管轄思想：首先，Schünemann批評由Jakobs提出、Freund加以援用的

¹⁶⁰ Michael Pawlik, „Das dunkelste Kapitel in der Dogmatik des Allgemeinen Teils“: Bemerkungen zur Lehre von den Garantenpflichten, in: Heinrich u.a. (Hrsg.), Strafrecht als Scientia Universalis (Festschrift für Claus Roxin), 2011, S. 931 (942-943) (以下簡稱：Pawlik, Bemerkungen zur Lehre von den Garantenpflichten); Michael Pawlik, Das Unrecht des Bürgers, 2012, S. 186 f.

¹⁶¹ Vgl. Michael Pawlik, Unterlassene Hilfeleistung: Zuständigkeitsbegründung und systematische Struktur, GA 1995, S. 360 (360).

¹⁶² Pawlik, Bemerkungen zur Lehre von den Garantenpflichten (Fn. 160), S. 943.

¹⁶³ Pawlik, Bemerkungen zur Lehre von den Garantenpflichten (Fn. 160), S. 944.

「組織管轄」，氏認為，此一表達方式乍看之下是社會學的用語，但是其實終究是一個語義學上的空殼子，因為在社會學上，人們把組織（Organisation）理解為社會的部分系統，系統係為了達到特殊的目的為目標，並擁有一個較高度的、形式化的內部構造，並透過「超個人的規定」以有別於「個體」，但Jakobs卻把組織領域等同於人的塑造，使用組織犯作為支配犯的同義字，根本上混淆了作為和不作為的存有論的結構，也無法說明作為和不作為中的等價性、類似性，蓋「因為我對於某件事隸屬我管轄，我就須對該領域輸出的危險負責」這本身僅僅能作為一規範性前提，倘若僅僅以此即認為行為人必須負起責任，那麼這種論證便不夠充分¹⁶⁴。

本文認為，Schünemann的批評並無法切中要害，因為正如前所述，保證人地位的實質根據和等價性是二個不同的層次，由Schünemann的批評可窺見，氏仍然無法擺脫等價性的魔咒，現在要證立的毋寧是實質根據的問題，而非等價問題。由於組織管轄權依照Jakobs的設定，係一種消極義務，刑法上課予人們消極不侵害他人的義務，本就是刑法存在的意義，其實，依照本文之見，組織領域的概念正確體現了刑法上「有支配方有犯罪成立」的前提思想¹⁶⁵，真正可能產生疑義的毋寧是體制管轄，後者涉及了刑法上是否應該承認積極的連帶性義務的問題。

關於體制管轄是否應該承認，首先應說明何謂「體制」。在社會學上，體制（Institution）理論是一個重要的理論，該理論的核心觀點認為，組織除了處在一個由物質所組成的物理環境以外，還有一個更重要的環境，就是由認知、觀念、風俗、文化、制度、價值觀等因素所構築而成的體制環境（institutional environments）¹⁶⁶。

¹⁶⁴ Bernd Schünemann著，陳志輝譯（註7），頁638-640。

¹⁶⁵ 不同意見參見許玉秀，保證人地位的法理基礎（註3），頁87-88。許教授認為支配是一種權力，而權力無法導出救助義務。

¹⁶⁶ See WILLIAM RICHARD SCOTT & JOHN. W. MEYER EDS., INSTITUTIONAL

在社會中，有許多導引及規範個人的行為的社會秩序及社會期待，體制就是泛指這些社會秩序及期待要求背後的機制。如果將一個企業機構看成是一個小型社會，為了讓所有機構內部之成員都有共同得以依循的行為模式或基準，機構中一定會有人事相關的規定，而這整套的人事規定以及其運作方式，便是一種體制¹⁶⁷。如果支配該體制運作的前提是一種法律義務，那麼我們就可稱此一體制為「法律體制」。而法律體制的創設，基本上必然地會對人們的行為自由產生某些限制，例如：在創設民法上的扶養義務後，我們即無法對「我不養育我的孩子和年邁父母」予以正當化，而這就是對於行為自由所作的限縮。

Jakobs以體制管轄來尋求保證人地位，係立基於連帶性（Solidarität）思想而生¹⁶⁸，這個出發點並沒有問題，蓋保證人地位的問題根源，主要就是刑法應該於多大的範圍內承認積極義務的問題，難題毋寧在於，什麼樣的體制方能作為刑法上足以作為保證人地位的體制？對於此一問題，Jakobs似也未能說明清楚，氏僅於教科書中提及對社會存續（gesellschaftlicher Bestand）有其決定性者，方得以作為刑法上的體制，而違反此一體制的不作為才會和作為等價（begehungsgleich）¹⁶⁹。然而，學者批評，對社會存續具有重要性或決定性是一個相當模糊的判準，更何況體制是否具有社會上重要性並非重點，反倒是應該討論「受威脅法益的保護必要性」¹⁷⁰。本文認為，Jakobs並未說明「為何」該體制具有「對社會存續的重要性」，倘若僅僅是提出家庭、收養監護關係等作為論證主體，恐怕就僅是以舉例代替說理，和早期的形式法律義務理論別

ENVIRONMENTS AND ORGANIZATIONS: STRUCTURAL COMPLEXITY AND INDIVIDUALISM 132 (1994).

¹⁶⁷ 關於體制的定義，也參見周漾沂（註5），頁236。

¹⁶⁸ Jakobs (Fn. 11), § 28 Rn. 16.

¹⁶⁹ Jakobs (Fn. 11), § 29 Rn. 58.

¹⁷⁰ 參見陳志輝（註7），頁309。

無二致¹⁷¹；再者，假使我們並未對體制設定一個較為清楚的前提，那麼恐怕將混淆德行義務和法律義務¹⁷²，形同恣意地設定、篩選刑法上適格的體制，如早年Jakobs認為民法婚姻法得以導出婚姻可作為一適格的刑法體制，然而，德國修改婚姻法後，離婚難度已經大幅度下降，此時Jakobs即將婚姻由體制管轄中抽離¹⁷³，如此一來，我們也可以推導出，Jakobs的理論完全建構於法律適用者對於體制的主觀想像和選擇，其無法擔保法安定性之危險，可見一斑。

另外，Pawlik以「確保個人存活的基本現實條件」證立保證人地位的根據，亦如Jakobs一般陷入同樣的困境，由於Jakobs和Pawlik的基本哲學思想來自Hegel式的國家觀和自由觀，例如Pawlik一方面在文中強調抽象法權是重要的，它能夠確保人們的個人法權領域會受到尊重，進而能夠自我決定並開展生活¹⁷⁴；然而一方面氏又強調必須犧牲一部分的權利，建立所謂的體制俾完善公民具體真實的自由¹⁷⁵，這二個觀點基本上就是處於矛盾的情形，蓋如同學者所言，一種強制公民主體重分配的體制，本身就是對於抽象法權的侵害，而不會是保護抽象法權的完整性¹⁷⁶。另外，「確保個人存活

171 同此批評已見許玉秀，保證人地位的法理基礎（註3），頁88；陳志輝（註7），頁308。

172 關於法律義務和德行義務的不同，刑法學和法哲學上文獻，vgl. Anette Grünwald, Zivilrechtlich begründete Garantenpflichten im Strafrecht?, 2001, S. 48 f.; Kurt Seelmann, Rechtsphilosophie, 1994, § 3 Rn. 11 ff.

173 Jakobs, Vorangegangenes Verhalten als Grund eines Unterlassungsdelikts (Fn. 156), S. 8, 10.

174 Pawlik, Bemerkungen zur Lehre von den Garantenpflichten (Fn. 160), S. 938.

175 Pawlik, Bemerkungen zur Lehre von den Garantenpflichten (Fn. 160), S. 944. 關於Hegel的實質、具體真實的自由（Wirklichkeit der konkreten Freiheit）和其法哲學思考中倫理性（Sittlichkeit）的聯繫，vgl. Katrin Gierhake, Der Zusammenhang von Freiheit, Sicherheit und Strafe im Recht: Eine Untersuchung zu den Grundlagen und Kriterien legitimer Terrorismusprävention, 2013, S. 122 ff.; 另外，將其運用於信賴原則基礎的思考參見周漾沂，反思信賴原則的理論基礎，收於：陳子平教授榮退論文集編輯委員會編，法學與風範——陳子平教授榮退論文集，頁57以下（2018年）。

176 周漾沂（註5），頁238。

的基本現實條件」和Jakobs的「對社會存續有其決定性」相比，毋寧只是同義反覆而已，從其文中脈絡出發，我們無法得出一個核心、亦即「何謂」「確保個人存活的基本現實條件」的滿足，如此一來，完全抽離得以依附的核心思想後，那麼恐怕僅是一種描述而非證立，無法正當化刑罰的制裁。

是以，Jakobs和Pawlik試圖由刑法以外的法規範來建構刑法上的體制，卻不對其設定條件加以明確限制，本文認為值得商榷。

（五）周漾沂教授「自由法秩序的補充性扶助體制」以及「風險管轄合意移轉」理論

1. 理論基礎

國內周漾沂教授也由規範性的視角重新反思保證人地位的實質根據，而認為以往學說所採取的支配、信賴或期待概念，都只是形成保證人地位規範性關係的反射結果，而不會是決定理由¹⁷⁷。氏由積極義務／消極義務觀點出發，並回溯至Kant實踐法哲學。Kant於道德底形上學一書中認為「法義務」是不侵害他人的義務，相對於法義務，協助他人的義務本質上是促進他人幸福的義務，並且將其歸納於德行義務之下，俾與法義務相區分。周教授藉此推衍出，原則上刑法廣泛地承認消極義務，然而，保證人地位的問題，即是刑法要在多大的範圍內局部地、例外地肯認積極義務的問題，蓋倘過度寬泛地承認積極義務意謂著對人們自由領域的侵害。

對應著上開積極義務／消極義務的概念，便是「風險連帶」以及「風險自我管轄」二個基本原則，一個以個人自由為基礎的法秩序，採取的基本立場應該是風險自我管轄原則，理由在於風險是自由的成本，沒有理由讓個人只得到自由的好處，卻不去負擔成本。

¹⁷⁷ 周漾沂（註5），頁217、219以下。

相反地，倘若肯定了法律上的積極義務，即意謂著一個人行動的附帶風險，可以轉嫁給他人管轄，風險實現的結果不是歸責給行動者，而是歸責於受移轉之他人。周教授因而指出，保證人地位之問題，同時也是在什麼條件下得以建立風險連帶性的問題¹⁷⁸。

接著，周教授開始說明，以實質不法、以「個人」為中心的自由法哲學概念僅僅能夠推導出普遍性的消極義務，而拒絕普遍性的積極義務。然而，周教授認為，在一個欠缺全面連帶性的法秩序下，在某些情形下仍然有必要建立局部的連帶性義務，使得公民之間以相互承擔社會生活風險，只不過此一連帶性的建立，必須恪守自由法基本原則。周教授嘗試提出了「自由法秩序之補充性扶助體制」和「風險管轄合意移轉」作為保證人地位的二個實質基礎¹⁷⁹。以下扼要地說明周教授理論之具體內涵。

2. 理論具體內容

首先是「自由法秩序之補充性扶助體制」保證人地位的部分，周教授反對前開Jakobs不設定一定前提的體制管轄（僅以「對社會存續具有重要性或決定性」），其指出，「自由法秩序之補充性扶助體制」並非不設限的生存照顧體制，而僅僅是對個人自由的補充。申言之，氏認為，自由和負責是一體的二面，「在一個以自由為理念的法秩序中，以刑法強制力加以支撐的體制，如果是以積極義務的履行為其功能，那麼其設立目的，只能侷限於補充個人自我負責能力的欠缺」¹⁸⁰。其也指出，個人在完整具有自我負責能力下的生活狀態，無論其真實生活狀態是否已經掉落到一定的水平下，本來屬於個人應自我負責的事項，就不允許刑法強制啟動任何補充性機

178 周漾沂（註5），頁225-226。

179 周漾沂（註5），頁236以下。

180 周漾沂（註5），頁239-240。

制來改善¹⁸¹。反面言之，自我負責能力有所欠缺者，在其完全無法管轄行使自由所引致的風險時，將風險全面地移轉於特定他人¹⁸²。

而具適格性體制的具體形態為何？首先，通說承認的「密切共同生活關係」保證人類型，必須嚴格地加以限縮，周教授認為，惟有「父母對子女」關係方得以承認具有保證人地位，且也僅限於對未成年子女，蓋後者欠缺自我負責能力，導致一般認識與判斷能力欠缺，此時父母對其即負有廣泛的保護義務，屬於一種原初責任，落入積極義務的範疇，並非若部分學者（黃榮堅教授）將之納入危險前行為，即消極義務來加以詮釋¹⁸³。再者，相較於未成年子女，對於成年子女即回歸自我負責原則，父母原則上並不負有廣泛性的保護義務，即使父母與成年子女有共同生活的事實亦然，蓋此一事實與補充自我負責能力欠缺之法體制建置理由無關，同理，子女對父母、配偶之間、兄弟姊妹之間或同居共財者之間，也必須回歸風險自我管轄原則而不再是風險連帶原則的場域¹⁸⁴。另外，周教授指出，父母事實上對於未成年子女無法盡保護義務（如死亡或其他原因）而將保護義務移轉於他人，又或是精神障礙或心智缺陷之人之「選定監護人」，都不是「自由法秩序之補充性扶助體制」脈絡之下擬討論的對象，而毋寧是下述「風險管轄合意移轉」的保證人類型¹⁸⁵。

其次，周教授開始論述「**風險管轄合意移轉**」類型的保證人地位的正當性和實際運用：氏指出，除了上開的補助原則外，原則上於自由法秩序和自我負責之脈絡下，難以建立一般性的風險連帶，唯一具有正當性的事由就是「當事人的自我意願」，亦即，在符合

181 周漾沂（註5），頁240。

182 周漾沂（註5），頁241。

183 周漾沂（註5），頁243-244。

184 周漾沂（註5），頁244-245。

185 同前註。

當事人之自我意願下，建立所謂「類體制」的關係。在雙方皆具備自我負責能力下，移轉風險之「自願性」不但是建立此一類體制的必要條件，也是充分條件。另外，周教授也指出，倘若不承認自願移轉風險管轄的保證人類型，那麼將解消由當事人所定義的社會交往活動，所影響的是個人的社會行動自由¹⁸⁶。

關於「風險管轄合意移轉」類型，氏舉出一例說明之：今天有二人一起單車環島旅行，倘若雙方未有約定之情況下，是適用風險自我管轄原則，假使一方跌落山溝，另一方也沒有救援義務，然而二人若有事先明確相約在對方陷入危難時施以援手，那麼此時即為風險管轄合意移轉，適用風險連帶原則。此所指的風險管轄合意移轉，係於合意之下有「事實上的移轉動作」，亦即須有一接受風險管轄之「交付」的動作，倘若只是事前的約定、先前預備的合意，並不足以建構一適格的保證人義務¹⁸⁷。然而，有些社會交往活動的實際運作模式，其實已經預設了某程度的風險連帶性，在這種情況下，決定參與社會交往活動，即意謂著接受他人控管風險的義務¹⁸⁸。例如救生員與泳客的關係，救生員的工作即是救援溺水的泳客，其在開放的泳池邊待命，即表示了其接受任何下水之人的風險管轄移轉要求，此時不以一個明確的移轉合意為必要，救生員也不得主張其無管控泳客風險的意願；相同的情形如登山團體，由於集體攀登高山也被視為一種風險連帶性的預設，所以除非有明示合意排除他人管轄風險，否則如同前例，一樣負有保證人義務¹⁸⁹。另外，可透過合意移轉的風險，未必是接受移轉者自己的風險，也可

186 周漾沂（註5），頁246-248。

187 周漾沂（註5），頁248。

188 此處必須要留意的是，周教授反對通說所謂的「危險共同體」類型的保證人地位，因為承認危險共同體的保證人類型，意味著一起從事高危險活動的團體成員，即必須承擔彼此的風險，然而，單純由「高危險」、「高風險」的事實，是否即能導出保證人地位，顯然是不可以的，結論上氏認為，仍然必須扣緊複數行為人有無移轉風險的合意。參見周漾沂（註5），頁250。

189 周漾沂（註5），頁249。

能是接受移轉者管轄的他人風險，特別是按照「自由法秩序之補充性扶助體制」的保證人地位，必須管轄自我無負責能力者之生活風險者，也可將風險移轉管轄給第三人，第三人因而對無自我負責能力者負有保證人義務，典型案例如保母承繼父母對於幼兒的風險管轄¹⁹⁰。

最後，周教授的「風險自我管轄原則」和Jakobs提出的「組織管轄」基本上相仿，所涉及的是一種與行動自由相對應的義務，人不能只享受自由的好處而不付出成本，進而將風險輸出予他人。然而，和Jakobs最重大的差異在於，不同於Jakobs將組織管轄涵蓋積極和消極義務，周教授認為，風險自我管轄原則所涉及的毋寧是一種消極義務，因為氏認為作為和不作為必須由人際關係來區分¹⁹¹，作為是「從無到有」地製造了新的風險，不作為是未消滅既存的、和行為人無關的風險¹⁹²。所以，在如此的背景理解下，氏反對通說承認的危險前行為類型的保證人地位，因為倘若犯罪結果的發生已經是行為人所創造的風險，那麼行為人所違反的即是消極義務，因而其應該屬於作為犯，而不是不作為犯，在危險前行為的狀況，是行為人為了實現自己自由而創造他人風險所致，這時候只要確實地將風險和風險實現結果歸責給行為人，追究其作為犯責任，就是使其充分地擔負行使自由的成本了¹⁹³。

3. 本文見解

本文認為，周教授提出「自由法秩序之補充性扶助體制」和「風險管轄合意移轉」作為保證人地位的二個實質基礎，將Jakobs教授模糊的體制管轄概念予以清晰化，並且嚴格限制保證人的成立

¹⁹⁰ 周漾沂（註5），頁248。

¹⁹¹ 周漾沂（註5），頁223。

¹⁹² 周漾沂（註5），頁252。

¹⁹³ 周漾沂（註5），頁254。

可能，這一點上是相當值得肯定的。另外，本文也認為，周教授正確地指出刑事實質不法的根據，並無落入形式法律義務理論「以民法或其他契約導出刑事不法」、以舉例代替說理的窘境，這點也相當值得贊同。然而，本文以下仍擬提出數點想法，以拋磚引玉，激起更廣泛的思考：

其次，本文對於周教授以人際關係來區分作為／不作為以及消極義務／積極義務的觀點容有疑問，舉例而言，在大洞旁邊未設置警示標誌，導致用路人跌落坑洞，按照一般的想法，屬於危險源監控或前行為類型的保證人義務之不履行，概念上應該是被劃歸於積極義務的範疇，惟周教授指出，從人際關係的角度而言，設置警示牌的行為不過是履行消極義務的附隨性作為而已，這種附隨性作為的可能性，邏輯上永遠會連結於違反消極義務之作為¹⁹⁴。對於此一看法，必須要由周教授的基礎思考路徑出發：首先，氏認為必須採取人際關係的觀點來區分作為／不作為，蓋吾人所處的社會，是一個人們彼此互動、交往而互相遭遇的社會，在最抽象的思考層次上，人們的互動形式有「干涉他人」和「不理會他人」的二種型態，所謂的「干涉他人」所指涉的是改變他人的既有狀態；而「不理會他人」則是放任他人既有狀態的進行¹⁹⁵。對應到刑法學上的術語，氏以「輸出風險到他人的法權領域」／「未撲滅他人法權領域內的既存風險」作為其區分作為／不作為的定義¹⁹⁶。從此一脈絡出發，在大洞旁邊未設置警示標誌，在其看來，該路面上的大洞根本不是被害人本身法權領域內的既有風險，蓋該大洞是由行為人無中生有的產物，邏輯上毋寧應該置於輸出風險的範疇，方為一貫¹⁹⁷。本文認為，這種說法乍看之下論理一貫，惟相當值得懷疑的是，基

¹⁹⁴ 周漾沂（註5），頁253。

¹⁹⁵ 深入的論述，參見周漾沂，刑法上作為與不作為之區分，科技法學評論，11卷2期，頁103（2014年）。

¹⁹⁶ 周漾沂（註195），頁106-107。

¹⁹⁷ 周漾沂（註195），頁112。

於人際風險觀點，是否就可以必然推導出「輸出風險到他人的法權領域」／「未撲滅他人法權領域內的既存風險」這一組辭彙，難道我們本於抽象的人際風險觀點，無法得出不作為係「未撲滅他人法權領域內的新生成的風險」嗎？頗值懷疑。再者，更令人起疑竇的是，在被害人掉落洞中的案例中，在挖洞的行為當時即評價為風險輸出，首先必須面對的質疑是，在挖洞當下根本無人在附近，何以被評價為輸出風險？依照其說法，此屬於「延遲輸出」的情形，故必須有人靠近時，未採取防阻措施（未大喊注意）才能被認為是輸出風險¹⁹⁸，然而，姑且不論此已經違背了日常生活一般經驗，更重要的質疑恐怕在於，倘若今天該雇工於挖洞時具有完全責任能力，而竟然完全不遵守施工規則而施工，導致事後有人跌落受傷，然而在跌落時該行為人已經處於無責任狀態時，依照通說的看法，前行為的作為（具責任能力）和後行為的不作為（喪失責任能力）在競合後，仍能夠最低限度評價到前行為的作為，但在風險延遲輸出的思考下，行為人得以輕易脫罪，恐生處罰漏洞；另外，倘挖洞的數位雇工本於犯意聯絡而挖掘陷阱，而相約不設置警告標誌，然之後於路人經過時，在工地現場只有一位雇工看守而該雇工仍未擺設警示牌，導致路人重傷，此案依照延遲輸出風險的思考，其他雇工並未輸出風險，而得以脫免制裁。就上開所示的案例可知，本文認為，原則上刑法規範上應該要評價的是，一個駕駛人摔落洞中的行為，而非評價挖洞行為的風險輸出，又以「延遲輸出」等違背一般社會交往的辭彙加以修飾。

另外，在上開脈絡之下，周教授反對危險前行為保證人類型，蓋氏認為由人際風險理論和風險自我管轄原則得以推導出，危險前行為是屬於「消極義務」的範疇，僅僅須追咎行為人前行為的作為即為已足，而毋庸再討論嗣後的不作為，否則極有可能落入重複評

198 周漾沂（註195），頁112-113。

價的危險¹⁹⁹。姑且不論是否有過度評價的問題，按照周教授對保證人地位提出之「自由法秩序之補充性扶助體制」，原則上只有被害人無法自我負責時，刑法才有介入、干涉的必要，然而，危險前行為正好是行為人製造了風險，使得被害人此時難以自我管轄、自我負責，此不正是補助性體制介入的最佳時機嗎？惟周教授並未討論前行為之後的「不作為」是否得以建構一體制，而僅僅認為評價「前行為」即為已足。蓋如上述，氏認為前行為之後的「不作為」僅僅屬於消極義務的附隨性作為，毋庸另外作評價。此雖然邏輯一貫地不討論保證人地位的問題（氏認為是作為犯），但正如本文上述的質疑，難道我們本於抽象的人際風險理論，完全無法演繹出不作為係「未撲滅他人法權領域內的新生成的風險」的可能嗎？是以，前行為類型保證人地位是否真的無法以不作為的「體制」來加以說明？恐待斟酌。

參、本文對保證人地位法理基礎的建構

一、回到原點：由作為和不作為的區別出發

本文於第貳章探討了德國學說和我國學說對於保證人地位實質法理基礎的分歧見解，撇開早期學說和Armin Kaufmann的形式法律義務理論不談，總結來看，大致上學說可以分為三個脈絡，一是信賴原則的存有論結構，二是偏向規範論的論述模式（許玉秀、Jakobs、周漾沂等學者），最後則是調合存有和規範，以事物本質的折衷方法論來去尋求實質之「法的發現」（Schünemann）。對於上開理論的評析，已如上述，以下本文將建構一套奠基於人類自由（*menschliche Freiheit*）的保證人地位，並回到事物本身去探討其存在意涵。

¹⁹⁹ 周漾沂（註5），頁254。

首先，刑法理論必定是建構於一套縝密的歸責概念之上，而非恣意以所謂的社會共識或是習慣法模糊帶過，實毋庸置疑，此尤其應體現於保證人地位這類法無明確規定的類型。其次，歸責概念必須以行為人所為的行為作為思考的起點，在此開啟了不作為是否得以納入此縝密歸責概念的入口。是以，我們如此得以窺見，重心在於作為和不作為的「共同性」，也就是等價性的意涵。在此本文擬回溯討論作為和不作為之概念，學說上有認為不作為根本無須附庸於作為，但也有認為，毋寧應由內心情緒來區分二者異同，蓋作為和不作為不應該由傳統自然主義、物理學的觀點聚焦於特定客體現象上的改變，這也表徵在不作為的因果關係的討論²⁰⁰。

本文以下將扼要討論筆者對於作為和不作為的想法（下文二），緊接著討論等價性問題以及最核心的保證人地位實質根據的問題（下文三），先予說明。

二、不作為和作為的差異析論

（一）不作為和作為本質上有別？兼論不作為因果關係理論

學理上有指出，不作為和作為的構造有別，不可能也不需要與作為等價，它是一種獨立於作為的犯罪態樣、型態，不作為侵害法益的強度和作為犯顯然不相同，法規範不應該無視於此一現實，而賦予相同的處罰²⁰¹。又學者並引了德國刑法第13條減輕處罰的條款作為一佐證²⁰²。德國通說也認為，不作為犯是純粹價值範疇的產物，而作為犯才是自然世界的物理現象²⁰³，又如同Jakobs於其刑法教科書中指出：「要由不作為推衍出因果關係是不可能的，故無論是運用條件理論或是假設的因果關係都不是很好的理解」，是故，

200 黃榮堅，基礎刑法學（下）（註2），頁696-697。

201 許玉秀，保證人地位的法理基礎（註3），頁89-93。

202 許玉秀，保證人地位的法理基礎（註3），頁93。

203 Vgl. Jescheck/Weigend (Fn. 12), S. 618.

Jakobs將不作為犯理解為欠缺因果關係卻仍須歸責的一種類型，這乃由事件自始不存在（Fehlen eines Ereignisses）來理解不作為犯和作為犯的差異。

反之，有另一派學者持全然不同的看法，Puppe教授指出，Jakobs將不作為解讀成一個「不存在的事物」²⁰⁴是不正確的，她反對通說對於不作為犯另眼看待，而認為不作為和作為都指涉一個事實（die Tatsache），二者均是描述一特定的現象。故氏反對通說以假設因果關係（Quasikausalität）來替代INUS條件理論（Insufficient but Necessary part of an Unnecessary but Sufficient condition）做為檢驗不作為因果關係之方法²⁰⁵。Puppe引用了奧地利哲學家維根斯坦（Wittgenstein）於邏輯哲學論（Tractatus logico-philosophicus）中的一段話：「重要的是，p與~p能夠說出同一件事情，因為它表明，在實在中，沒有任何事物對應於“~”這個符號。否定符號在命題出現，並不足以呈現它的意義（ $\sim p = p$ ）。p與~p這兩個命題有相反的意義，但對應於它們的，卻是同一個實在。」（4.0621）²⁰⁶，表明了她對於「不作為」的立場²⁰⁷。另外，我國黃榮堅教授也表達類似的看法，氏認為通說沒有體察到，作為和不作為的差別，並不在於

204 Vgl. Jakobs (Fn. 11), § 7 Rn. 25.

205 Vgl. Ingeborg Puppe, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen (Hrsg.), Nomos Kommentar zum Strafgesetzbuch, 4. Aufl., 2013, Vor § 13 Rn. 56, 117 ff. 關於INUS理論和傳統條件理論的差異，see JOHN LESLIE MACKIE, THE CEMENT OF THE UNIVERSE: A STUDY OF CAUSATION 62 (1974)；另外，Hart和Honoré也力主此一理論解決多重因果鏈難題，而將稱其為NESS-Test（係necessary element of a sufficient set之縮寫），之後由Wright教授加以總結。此部分可參見Puppe, a.a.O., § 13 Rn. 109 f.

206 Vgl. Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, 1922, 4.0621, „Dass in einem Satz die Verneinung vorkommt, ist noch kein Merkmal seines Sinnes ($\sim p = p$).“, online verfügbar unter <https://people.umass.edu/klement/tlp/tlp.pdf> (last visited Sept. 3, 2018). 中文翻譯本參見涂紀亮編，維特根斯坦全集（一），頁208-209（2003年）；深入討論請參見苑舉正，從方法論的角度論維根斯坦與波普的「否定」概念，台灣哲學會2007年度學術研討會，東海大學主辦（2007年10月20-21日）。

207 Puppe (Fn. 205), § 13 Rn. 57.

肉眼能不能看得到的問題，而僅僅是建立在情緒上的描述語言不同，對於一個跑在馬路上的人，我們可以說他在趕著到銀行繳款（作為），也可以說他不唸書（不作為），差別在於我們的情緒在哪裡。結論上黃榮堅教授認為，假使認為不作為是有異於作為的物質現象，甚至是一個不存在的現象，都是受限於文字表面所形成的認知障礙²⁰⁸。

本文以為，作為和不作為雖然在刑法檢驗上之結構有別（如：刑法第15條），但通說認為不作為並無具體的現象，甚至該現象是不存在的，係侷限於思考或文字上的表象，是一種純粹由自然主義、描述性觀察的觀點，並無規範上的意義，國內也早已有學者提出批評^{209、210}。再者，通說認為，作為犯和不作為的差異在於，不作為並無施加力量，故不可能有外在的改變，然而，德國通說早已揚棄了自Engisch以來，以「能量」或「力量」的施加與否來區辨作為或不作為²¹¹，何以在不作為因果關係的領域卻仍然停留在此一階段的思考？講得更清楚一點，以自然主義觀察下的「假設的因果關係」、「準因果關係」來替代原本作為犯的「條件因果關係」²¹²，

208 黃榮堅，基礎刑法學（下）（註2），頁697。

209 周漾沂（註195），頁97。

210 在哲學上，存在和虛無一直都是熱門的話題，例如沙特（Jean Paul Sartre）。與以往的哲學一直圍繞「存在」的意義進行討論相反，沙特將「虛無」作為研究的主題。在《存在與虛無》這本哲學鉅著中，著名的「咖啡館」的例子中，沙特與朋友皮埃爾約好在咖啡館見面，在皮埃爾還沒到之前，沙特一個人在咖啡館中等待，此時，咖啡館中孩子的喧鬧聲、玻璃餐具的碰撞聲交織在一起，人們都在聊著各種各樣的話題。這些「存在」相對於「皮埃爾不在」這樣的事情而言，完全不具有任何意義。這裏，只有「皮埃爾不在」這樣的事情才是真正重要的。這個案例極為精確地展示了「不存在」意義的重要性，依照筆者的解讀，存在和虛無恐怕是一個人情緒上的期待與否，說得更遠一些，中國古諺：「情人眼裡出西施」也是一樣的道理。除了沙特以外，20世紀最重要的現象學哲學家海德格（Martin Heidegger）也大量探討虛無的概念，關於虛無在哲學上的討論，有興趣的讀者可參見Jim Holt著，陳信宏譯，世界為何存在？（2016年）。

211 周漾沂（註195），頁95以下。

212 參見許玉秀，前行為的保證人地位與客觀歸責理論初探（註3），頁311-312；

卻又支持「評價觀點」而捨「能量觀點」來界分作為犯和不作為犯²¹³，通說的標準顯然是有待商榷的²¹⁴。

是以，本文認為，條件公式完全可以應用在不作為的判斷上，將條件公式：「倘若行為人不做該行為，結果即無從發生，該行為即係結果發生不可想像其不存在之條件」套用至不作為犯即成為：「倘若行為人不做該袖手旁觀之行為，結果即無從發生，該袖手旁觀之行為即係結果發生不可想像其不存在之條件」，故本文認為不作為於條件公式得以「袖手旁觀的行為」無窒礙地理解。最後，本文認為，運用條件因果關係公式時，確認因果關係之機率高低和通說所謂的「幾近確定公式」²¹⁵相仿，需要達到幾乎可以完全確定該

徐育安，不作為犯之因果關係，收於：公益信託東吳法學基金編，不作為犯的現況與難題，頁162-163、171（2015年）。

²¹³ 關於作為與不作為區分的學說，整理已見周漾沂（註195），頁91-101。

²¹⁴ 此處可能會受到質疑的是，筆者並未認真提出界分作為與不作為的觀點，而本文所採的觀點，勢必將回到作為與不作為的區分，否則即有循環論斷之嫌。其實，作為與不作為的界分有其困難而模糊，宥於篇幅，本文僅能略述一二：作為與不作為的區分，刑法學界向來有二種相對立的觀點，一種是由自然主義的進路出發，其中又可分為Karl Engisch提出的能量說和之後建立於其上的因果作用說（Armin Kaufmann、Hans Welzel），本說認為，作為是行為人對於特定方向積極地投入能量，而不作為則係未朝著特定方向投入能量，因果作用說則於其上做了進一步的衍伸，認為作為即係積極的導致因果進程，而不作為因為並無物理學上的動靜，故於因果關係檢驗上必須採取假設之因果關係，這也是通說於因果關係的判斷上，對不作為因果關係另眼看待的原因，然而，本文認為，單純由現象變動來觀察作為與不作為顯然是有問題的，蓋生活上大多數的情形上，我們實難斬釘截鐵地認為一現象究竟係作為或不作為（如乳癌案即係適例），故毋寧應採取多數說之評價性之規範觀點，考察該行為之「非難重點」來決定該行為究竟是作為或不作為。當然，非難重點的規範評價說仍有其盲點，Jescheck、Weigend即嚴厲的指出該理論於操作上將流於恣意，最終無疑係憑藉法律適用者之法感覺（Jescheck/Weigend (Fn. 12), S. 604.）。本文原則上採取後說，蓋作為與不作為的區別並不在於物理上的不同，而在於人們觀察事物的主觀切入點之差異，故於因果關係判斷上也不宜採取和作為犯不同的標準，否則將造成體系的不一致（即作為與不作為的區分採非難重點說，因果判斷卻又採取自然主義的思考）！

²¹⁵ 德國聯邦最高法院（BGH）實務見解對於不作為因果關係之機率，發展出一「幾近確定可能性」（an der Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit）之公式，

行為人袖手旁觀之行為會造成結果發生（通常係90%以上的強度），方能確定該不作為與結果間具有因果關係。

（二）規範評價的差異作為區分作為和不作為的關鍵

由上面敘述我們得知，作為和不作為是人們觀察事物角度的不同，而不是在於它們事物本質上的差異，本文採取的毋寧是一種規範評價上的差異來區辨二者，然而，終究還是有所不同，這個鴻溝如何跨越呢？便有賴於保證人了。

讓我們再次回顧保證人的歷史，當時的德國學界，瀰漫著一股對立氣息，自然主義因果論和基爾學派的法義務說僵持不下。而1930年代，也正是新黑格爾主義和現象學二股思潮影響整個刑法體系的高峰，此使刑法學界由自然主義因果論重視犯罪的結果整個轉移到行為本身上，人類會作出某一行為，係出自於精神的驅使，行

倘行為人從事了法律要求其履行的作為義務，結果「幾乎可以完全確定」不會發生時，即可認定該不作為係結果發生之原因，這個因果律的要求無疑是相當高的，Stratenwerth/Kuhlen和Otto力主的「風險降低理論」，便是此一理論的反動。他們認為，德國通說和實務見解所採的幾近確定可能性公式存在著疑問，蓋作為犯和不作為犯的結構存在著明顯的差異，那麼我們就不應該以作為犯的條件理論來檢驗不作為犯，即使是改良過後的準因果模式亦然；其次，幾近確定可能性的公式係一極為嚴格的因果關係檢驗模式，行為人之不作為須達到「幾乎可以完全確定」其實施法所期待之行為，結果不會發生時，我們方能夠將該結果歸因於他，然而，倘若結果發生的可能已經有了90%，法院實務卻以結果無法達到完全確定而判決其無罪，如此是否合理？無疑地會造成刑事處罰的漏洞，況且，我們於作為犯的因果判定上，只要行為人之行為對於外在世界造成些微的變動，該行為都可以通過條件理論的檢驗，何以於不作為犯的因果檢驗上，標準突然變得如此嚴格？這明顯地抵觸平等原則。對此請參見Otto (Fn. 10), § 9 Rn. 98 f.; Günter Stratenwerth/Lothar Kuhlen, Strafrecht Allgemeiner Teil, 6. Aufl., 2011, § 13 Rn. 54; Joerg Brammsen, Erfolgszurechnung bei unterlassener Gefahrverminderung durch einen Garanten, MDR 1989, S. 123. 德國文獻上對二種不同意見的詳細分析參Luis Greco, Kausalitäts-und Zurechnungsfragen bei unechten Unterlassungsdelikten, ZIS 8-9 (2011), S. 674 (674-681). (Greco進一步地對於風險降低理論做精緻的思考，並指出反對意見的弱點；結論上其認為，如果得以對具體型態結果於空間和時間上做出定義，那麼風險降低理論可能並不如批評意見所言有取代因果關係的疑慮，反而得以對可罰性做出限制。)

為本身彰顯在外界的意義便是意志的決定，在這個脈絡底下，Welzel提出了影響刑法學界甚鉅的目的行為論²¹⁶。而在不作為犯此一主題下，Nagler提出的保證人說正好契合了這個時代的思潮，氏認為，法定的構成要件並非表徵行為與結果之間的原因力或因果進程，而毋寧在於該行為表現出行為人之意志²¹⁷，也就是說，構成要件行為的主要特點，在於此行為係人的意志形之於外在的表徵，是以倘若不作為表現於外之意志和作為相同時，我們可以對不作為賦予和作為相同的評價²¹⁸；又，不作為何以和作為表現出相同之意志內容呢？按照Nagler的想法，規範可以分成禁止規範以及誡命規範，而誡命規範是被包括於禁止規範中，屬於「以大包小」的關係，而禁止規範係面向所有、一般法規範主體所發出，惟誡命規範僅對一部分的法主體生效，後者所謂的「一部分」即是為後世傷透腦筋的實質根據問題（按：本文主題）²¹⁹。

Nagler的貢獻在於確立了等價根據，也確立了保證人地位於犯罪階層體系中的「構成要件」階層，然而，對此國內仍有學者認為保證人地位屬於罪責階層的「期待可能性」的問題，黃榮堅教授明白於教科書中採取此一立場，氏指出，不法的核心概念在於不被容許的利益侵害，有責性則是對於迴避既定的不法（失衡的）侵害的期待可能性問題的考量，他舉小孩溺水的例子說明：今天某甲看到自己的小孩子溺水卻置之不理，可能因其不作為且具有保證人地位，而構成殺人罪，相對地，倘若路人袖手旁觀，由於路人不具備

216 Welzel的基本思想以「人的不法」為中心，對整個德國刑法學界早年受自然主義的「結果不法」提出批評，此深深影響戰後的刑法學數十年，時至今日，我們仍然是活在目的行為論和早期古典體系的碰撞當中，70年代目的理性體系（機能主義）的出現，即是如此。關於Welzel的刑法思想，中文文獻可參見許恒達，行為非價與結果非價——論刑事不法概念的實質內涵，收於：法益保護與行為刑法，頁88以下（2016年）。

217 Nagler (Fn. 23), S. 28 ff.

218 Nagler (Fn. 23), S. 54.

219 Nagler (Fn. 23), S. 59-60.

保證人地位，所以不構成犯罪，然而，在小孩子溺水的那一刻二人現實上的利害關係都是一樣的，並非因為某甲具有保證人地位方導致了整件事情在利害關係上的失衡（不容許的侵害）²²⁰；另外，黃榮堅教授也認為，倘若我們肯認人類社會相互救助的基本理念²²¹，我們似乎也應該將保證人地位的概念置於有責性的階層，假使如通說所言，保證人地位屬於不法層次的問題，不僅僅是放棄刑法上行為規範的訴求，而是根本放棄社會意義的行為規範訴求，傳達了「沒有必要救助陌生人」的一個規範訊息，容有疑問！

關於黃榮堅教授的見解，本文容有不同想法，首先，黃教授認為懶惰是人的天性，不作為更是基本人權²²²，這種看法本文完全同意，立基於自由法哲學思想和刑法謙抑、最後手段性上，不應該廣泛地承認刑法上的積極義務，然而，氏卻又於文中提及類似社會相互扶助的連帶思想，認為路人的不救助一樣具有不作為的不法，保證人地位僅僅是罪責要件期待可能性的問題，此段論述頗令人疑惑，一個市民享有的基本人權，為何會因為行使而構成刑事上的不

220 黃榮堅，基礎刑法學（下）（註2），頁701-702。

221 德國刑法第323c條的不作為救助罪即是社會連帶的典型條文，關於此條項的詳細介紹，除了上述Pawlik (Fn. 161)的文章外，亦可參見Kahlo (Fn. 61), S. 273 ff. 在《聖經》路加福音第10章第30節中有所謂的「好的撒瑪利亞人」故事，該故事描述了撒瑪利亞人救助處於危難的以色列人：當一個以色列人受到強盜的襲擊而身負重傷、處於死亡邊緣時，祭司和利未人都視若無睹、大搖大擺地從傷者面前走過，只有一位撒瑪利亞人抱著憐憫的心救助了這個人，這就是所謂的「好的撒瑪利亞人」故事。後來產生了借助《聖經》的這個故事來命名的「好撒瑪利亞人法」(Good Samaritan law)，影響遍及西方國家，德國刑法第323c條便是此原則的體現。現代意義的社會連帶，則是政治哲學和涂爾幹社會學發展的產物，其大致主張為了實現公民最大福祉，公民不能自顧門前雪，僅在自身管轄領域上負責，而是應建立某種集體互助關係，使彼此相互承擔風險，此在風險社會看似有其正當性，但是否適用於刑法義務上，則莫衷一是。關於刑法學與社會連帶，國內文獻精彩的討論參見周漾沂，論攻擊性緊急避難之定位，臺大法學論叢，41卷1期，頁404以下（2012年）；德文文獻近年來已有專書討論，vgl. Hirsch/Neumann/Seelmann (Hrsg.), Solidarität im Strafrecht: Zur Funktion und Legitimation strafrechtlicher Solidaritätspflichten, 2013.

222 黃榮堅，基礎刑法學（下）（註2），頁721。

法？且一方面肯認不作為是與生俱來的基本權，卻又承認社會廣泛的連帶互助，如此論述，是否存在一矛盾點，恐怕仍有待斟酌²²³。

三、保證人地位的實質根據——雙重歸責基礎的提出²²⁴

(一)「因果流程的支配」和「社會角色」於刑事不法歸責中的意義

行文至此，本文耙梳了德國和我國學者對於保證人地位實質根據的見解，其實，尋覓實質根據的道路係崎嶇的，而這就是一種法與其他倫理義務的融合過程，而於積極義務的有限框架下，作內容上的填補。本文以下將嘗試提出對於保證人地位實質根據的建構，冀能拋磚引玉，激發更廣泛的討論。

正如本文所述，作為犯和不作為犯的本質並無不同，差別僅僅在於規範上、情緒上的不同，所以原則上二者之可罰性依據、源頭必須建構於同一套體系上，只有在規範、體制建構上作有別於作為犯之理解，方能避免體系和邏輯上的謬誤。依照Roxin教授於1963年教授資格論文中指出，作為犯的處罰依據在於犯罪支配理論（Tatherrschaftslehre）的行為支配（Handlungsherrschaft），行為支配係指行為人對於因果流程的進行具有完全的掌控，這樣的觀點雖然仍停留於一上位的、抽象的層次而受到批評，然本文認為，行為支配的想法符合了刑法的原初期待和目標，蓋一個對於因果流程毫無掌控的人，倘若刑法對其加以動怒，那麼就悖離了人類自由的圖

223 相類似的批評已見，許澤天，不純正不作為犯的正犯判斷標準，收於：公益信託東吳法學基金編，不作為犯的現況與難題，頁444（2015年）。

224 筆者必須澄清，通說將作為（支配）可能性和保證人地位做不同層次的檢驗，而認定二者是互不相干的二個檢驗要素，但筆者在本論文中嘗試合而為一，而認為保證人地位的基礎即在於具有支配的義務違反之上，主要的理由是基於一個簡單的思考：因為我們具備行動可能（自由），才有可能進一步推導出行動必須（自由的限制；義務），這二者無疑是纏結而連貫的；當然，通說將二者分開討論，並非謬誤，只是思考進路的不同而已。

像。不作為犯也是如此，除了和作為犯有著完全相同的目標——對於因果流程支配外，在一個人際相互往來的現代社會，原則上人們或多或少都被賦予一些角色期待，而在角色期待以外的事物，原則上本於自由權的消極面，是無法苛求人們對之加以行動的²²⁵。是以，在證立並劃定保證人地位的實質根據時，「支配」和「角色期待」是二項必須要先予以把握的重心。

首先要討論的是「支配」，由於支配概念來自於社會學，所以其具有強烈的可塑性，它指涉的可能是事前的造成結果原因的支配，也可能是對於整個因果進程的支配，其中Schünemann教授的「對結果發生的重要原因」有所支配，是一種事前、事實上的支配，已如前述，這種支配理論試圖將作為犯與不作為犯賦予可以相類比的基礎，然而，雖然Schünemann教授聲稱其方法論來自物本邏輯（Sachlogik），其在某些案例當中卻似乎有規範性支配的痕跡（例如：孕婦對於胎兒或甫出生嬰兒之例，參考前述）。後者「因果流程的支配」指涉的毋寧是實際上、存有的支配，是因果論的進化版。本文認為，雖然來自19世紀因果論和實證主義思想的支配於方法論上，受到很多批評，尤其是1920年代西南德意志新康德學派開始撻伐19世紀風行的因果一元論後，自然主義的刑法觀受到很大的檢討，然而，1930年代末期的Welzel提倡的目的行為論，其背後的指導原則——胡塞爾和海德格現象學——仍然是藉由存在哲學（Existenzphilosophie）的觀點認識這個世界，是以，時至今日的「新古典暨目的論綜合刑法體系」仍然保留著存有論以及支配的影子，並不足以為奇²²⁶。本文認為，方法論的爭論，雖然牽涉到吾人

225 憲法上的討論參見陳慈陽，憲法學，3版，頁525（2016年）。

226 關於20世紀德國刑法學以及刑法犯罪階層體系的流變，背後蘊含著三股哲學思潮的拉鋸戰，分別為新康德主義的方法二元論（嚴格區分應然和實然）、面向事物本身的現象學派（Husserl和Heidegger）導出的存有論、物本邏輯（方法一元論）以及新黑格爾主義。本文目的並非探討刑法基本理論的發展和背後的哲學意義，故不另贅述。詳細論述可參見許玉秀，犯罪階層體系及其方

對於這世界的理解，但不可否認支配仍然是一個人足以被刑法歸責的基礎，而背後的道理即在於限制刑罰權的發動，例如我們難以想像，一對正在峇里島度二次蜜月的夫婦，僅僅因為身分上、規範上對孩子負有扶養義務，即要對於遠在臺灣家中17歲兒子割腕自殺負責；也難以想像，一位遠在導師辦公室的國中導師，要對於在體育課突發癲癇而不治的學生負責，僅僅因為家長將教養保護權合意移轉於學校，即構成不作為的過失致死罪。原因都在於，二者雖然在民事法規範上均具有管轄或支配之可能，但事實上二者於行為時（*ex ante*）都不具有掌控或主導整個因果流程的進行，是以，均不是刑法應予歸責的對象。

是以，首先我們確立了行為人對於因果流程的支配、掌控是不法歸責的核心，本文將其稱為不作為犯的「第一歸責基礎」，然而，是否行為人具有因果流程的支配，我們就應該毫無保留地將該作品（*Werk*）歸咎、算帳到該人手上呢？在此牽涉到的即為「角色期待」。何謂角色期待呢？簡言之，就是在一個高度分工、精細化的風險社會，每個人扮演著不同的角色，而社會上對於不同的角色便會賦予不同的期待，例如我們會期待醫生能夠知悉病原體並治癒患者、期待保姆照顧好嬰兒、期待服務生上菜時不大聲說話避免口沫噴至飯菜內等等，這些社會賦予的期待，有些來自規範（例如醫術準則、律師倫理規範），而有些來自於約定成俗的習慣，角色期待在法秩序下扮演著不可或缺的一環，蓋我們並不要求人需要為自己不熟稔的領域負責，縱使今天保姆知悉嬰兒感染了某種病毒（該保姆或許是藥學系出身），但那並不重要，因為角色只期待她／他盡到撫育孩子的義務而已，超出這部分的認識，不在刑法規範的管轄範圍，頂多只具有民事求償或是道德非難之可能。

法論（2000年）；許玉秀，當代刑法理論之發展，收於：王兆鵬編，當代刑事法學之理論與發展——蔡墩銘教授榮退感念專輯，頁10以下（2002年）。

關於「角色期待」於刑法學上的思考，Jakobs在教科書中舉例，某個生物系的學生，依據他的專業和背景知識，在一道沙拉中發現含有劇毒的蘑菇，仍然悶不吭聲地將其端予顧客食用「蘑菇案」²²⁷，Jakobs指出，不僅僅是在不作為犯的領域有保證人地位的思考，作為犯亦然²²⁸，客觀歸責理論中的特殊認知（Sonderwissen）問題便是其中的典型。另外，對於「不具有保證人地位」作為犯特殊認知問題的處理，Jakobs和Roxin學派不同，很重要的源頭來自於二者對於「刑法要保護什麼？」有著迥異的認識²²⁹，相較於Roxin著重以法益保護作為指導原則，Jakobs吸收了Luhmann的學說，以規範的維護奉為主臬，而對於規範效力的維護，乃透過「角色」來具體運作；角色是規範的化身，社會規範通過各種各樣的角色具體地指向行為人，通過規範保障社會的同一性，以及維護規範的效力，都意味著要穩定各種既存的社會角色；最後，角色也是不法歸責的基礎，在一個匿名的社會裡，如果人們符合了角色的期待，就毋庸擔心被歸責的可能，否則，如果行為人已經符合了社會期待的要求，卻僅僅因為特別認知而受到不法歸責，無疑將形成「誅心」的刑法適用²³⁰，準此，在上面的「蘑菇案」中，該生所從事的社會活動僅僅與服務生的角色有關，他僅須按照社會對於「服務生」的期待行事即可，縱然他事實上可以挽救顧客的生命，然而這並不重要，因為刑法首要的並不是保護法益，而是確認社會的同一性。該生的所作所為符合了社會對服務生此一角色之期待，並無違反角色的要求，因此不存在可被歸責的實質基礎²³¹。本文不擬對於「刑法

227 Vgl. Jakobs (Fn. 11), § 7 Rn. 49 f.

228 Jakobs (Fn. 11), § 7 Rn. 56 ff.

229 近期對於Jakobs的刑法根本思想有完整闡述者，請參見王效文，刑罰目的與刑法體系——論Günther Jakobs功能主義刑法體系中的罪責，成大法學，30期，頁155-186（2015年）。

230 Vgl. Günther Jakobs, Tätervorstellung und objektive Zurechnung, in: Dornseifer/Horn/Schilling (Hrsg.), Gedächtnisschrift für Armin Kaufmann, 1989, S. 271.

231 Vgl. Jakobs (Fn. 11), § 7 Rn. 50.

擬保護之客體」如此高層次的問題深究，然仍希望藉由Jakobs教授對於社會角色於刑法上的意義，來說明縱使某些情形具有因果流程的支配，但是不應該被歸責的情形。如以下【案例1】、【案例2】：

【案例1】：某甲和某乙係一對年輕夫妻，平日工作繁忙，二人育有一子丙。丙年僅一歲，尚無自我生活能力，故甲乙聘請戊女擔任保姆。一日，甲乙均外出工作，在家中的年邁母親（甲之母）因高血壓而昏倒在地，此時戊女目睹此一場景，卻因為其與甲之母親早有嫌隙，而不願意伸出援手，導致甲母死亡。

【案例2】：某甲於清晨五點鐘行經一巷道，忽然發現前方有一老嫗跌落水溝，此時無其他路人經過，某甲下車看了一眼，即匆匆離去，該老嫗之後送醫因失血過多而身亡。

以上二個案例，行為人對於整個因果流程都具有支配，然而，倘若我們對於保姆不救治年邁的母親、路人不救治跌落水溝的老嫗也加以非難，無疑是承認廣泛的社會連帶思想，然而，假使我們秉持著人類自由和刑法最後手段性的想法，廣泛、毫無限制的社會連帶義務是無法被整合進刑法義務的²³²，縱使於民法上，連帶思想也僅只作為一種獎賞，而非義務或誡命，無因管理即為一適例²³³。由此也可以看出，堅持單一標準（支配）的不合理性，蓋根本原因在於，支配係完全由物本邏輯推衍而生，我們之所以時常會誤以為支配就是保證人根據的一切源頭，或許是因為多數情形下它和（法）規範間產生聯繫（如：父母和幼童、先生對妻子），然而，正如上

²³² 相同見解參見周漾沂（註5），頁231-235。

²³³ 我國民法第176條規定：「管理事務，利於本人，並不違反本人明示或可得推知之意思者，管理人為本人支出必要或有益之費用，或負擔債務，或受損害時，得請求本人償還其費用及自支出時起之利息，或清償其所負擔之債務，或賠償其損害。第一百七十四條第二項規定之情形，管理人管理事務，雖違反本人之意思，仍有前項之請求權」。傳達了一項基本觀念：即便是不涉及人身自由、較不具有苛酷性的民法典，都拒絕為廣泛的連帶義務背書。

開【案例1】、【案例2】所示，支配和規範產生聯繫恐怕僅是偶然，而非必然。

準以此言，本文的基本構想在於，雖然行為人對於因果流程的支配是不法歸責的前提，也是極其重要而不可或缺的關鍵，但單純藉由支配即欲統一天下的雄心，恐怕會有所闕漏，因為此僅能說明作為犯和不作為犯的「相同點」而已，故本文於「第一歸責基礎」——支配確立後，加上「第二歸責基礎」，也就是前述的「角色期待」標準，申言之，我們於確定行為人對於整個因果流程的進行具有支配後，必須進一步地探討該行為人所扮演的社會角色為何。以上開的【案例1】、【案例2】作說明：【案例1】中，保姆對於年邁母親擁有完全的支配，對於因果流程的進行也瞭若指掌，然而，無論是依據和主人訂立的契約（契約的承擔即代表主人對於保姆應為何種行為的期待，本文於後面有詳細說明），又或是刑法規範上對於保姆的期望，我們均無法推導出保姆有照料年邁母親的義務（這裡也不存在有附隨義務的情形），是以，在「第二歸責基礎」的招牌下，即排除了保姆的歸責，其不負有保證人義務；又於【案例2】中，雖然於清晨五點鐘杳無人煙的街衢上，某甲對於跌落的老婦人有支配，且能夠完全控制因果流程的進行，然而，對於行人、路人的行為期待，我們只課予其遵守交通規則、行走於人行道上的義務，並無法導出用路人有照料陷入無助之人的義務，在實證法未規範一般救助義務（如德國刑法第323c條）下，後者只能被認為是標準的德行義務，是以，某甲亦非保證人，無法因此而被歸責。最後，此一歸責標準也可以套用於周滢沂教授於文中舉出的「老農救助案」上，在人煙稀少的山徑上，雖然對於登山客的失溫或山難，老農夫具有支配，然而，我們無法對於老農長期的好意施惠，推導出老農已被賦予救助登山客的社會角色期待，反倒應由規範本身出發，來推導出老農夫僅具有和一般居民相同的義務而已，故老農縱使放任因果流程進行，也不構成不作為殺人罪。

(二) 排他性支配——區分「排他支配」以及「支配領域性」

1. 學說介紹

日本學者西田典之提出「排他性支配」作為不純正不作為犯保證人地位之基礎，西田教授於其刑法總論教科書中指出，作為是對於指向結果的因果進程的設定，那麼不作為便屬於對於因果流程的放任，為此，不作為要與作為具有構成要件等價值，不作為者就必須將正在發生的因果進程控制在自己掌中，即基於自己的意思而獲得排他性支配。倘若非基於自己的意思之支配，僅僅能被稱為「支配領域性」，以區別排他性支配。在「支配領域性」的場域，由於缺少了「基於意思」這一部分，作為這一部分的替代，就必須存在父子（或母子）關係、建築物的管理人員、安全保護人員等社會持續性的保護關係，唯有在此限度之內，才考慮規範性要素²³⁴。

西田教授的想法，主要區分支配為「排他性支配」以及「支配領域性」，二者主要的區別在於「自己的意思」的有無，氏舉出一個例子，假使早上起床看到大門口有一棄嬰，雖然是位於自己的大門口，但是此並非基於自己的意思，所以僅僅是支配領域性的關係，必須再尋覓有無規範性的要素方能加以歸責²³⁵。

2. 本文評析

本文認為，排他性支配理論的確是值得傾聽的見解，西田教授正確地指出，作為犯和不作為犯的共通點即在於因果流程的掌握，這和本文的「第一歸責基礎」相同，而有別於Schünemann教授的事前支配理論。然而，區分支配為「排他性支配」以及「支配領域性」是否有其說服力，恐不無疑問，因為保證人地位原則上定位於客觀構成要件，故以自己的意思有無來區辨二者似乎混淆了構成要

²³⁴ 參見西田典之著，王昭武、劉明祥譯，日本刑法總論，頁128-129（2012年）。

²³⁵ 同前註。

件主客觀的分界。是以，本文認為，排他性的要件似乎是一項多餘的要求²³⁶。本文認為，無論是父母不照顧年幼的嬰兒，抑或是門口花圃突然發現一棄嬰，二者客觀上對於因果流程都具有支配，符合「第一歸責基礎」的要求，然而正如上開所述，此時仍然必須進入「第二歸責基礎」，也就是角色和規範的評價，其中，父母的角色依照民法第1084條規定，負有保護和教養的權利義務，法規範期待父母應為，卻不為其必要的扶養，得以構成不作為犯²³⁷；然而在棄嬰的例子，住戶並不具有扶養棄嬰的義務，社會反而應該是對於主動聯繫社福機構的住戶給予稱讚，故此時不具有積極義務，不應課責於漠不關心之住戶。

另外，本文所採的雙重歸責基礎理論和排他性支配理論的共通點在於，對於積極義務的成立，均設下了嚴格的前提——行為人必須先對於因果流程有支配，方才能進一步考量積極義務的證立。這一點和Jakobs的組織管轄／體制管轄有所不同，從Jakobs的論述可知，氏將組織管轄和體制管轄「並列」為不作為犯保證人地位的雙重根據，而不是前者做為後者的前提，也就是本文前面所批評的：「Jakobs試圖由刑法以外的法規範來建構刑法上的體制，卻不對其設定條件加以明確限制」，這種對體制管轄，也就是承認刑法上的積極義務未設立一定前提，恐怕得出的結論也是任人憑說，無法擔保安定性，最終仍然是市民自由的嚴重戕害。由以下二圖即可得知，本文承認的保證人地位範圍較Jakobs來得小：

236 結論上相同，參見山口厚著，付立慶譯，刑法總論，頁88以下（2011年）。

237 國內文獻和本文做相似的解讀者參見蔡芸琦，保證人地位之判斷模式，收於：陳子平教授榮退論文集編輯委員會編，法學與風範——陳子平教授榮退論文集，頁241（2018年）。當然，此牽涉到民法上的義務是否得以直接援引，俾構成刑法上的義務，此一問題清楚顯示出，本文所提出的「第二歸責基礎」——角色與規範性期待，必須要加以具體化和細緻化，本文將於下一部分詳細論述之。

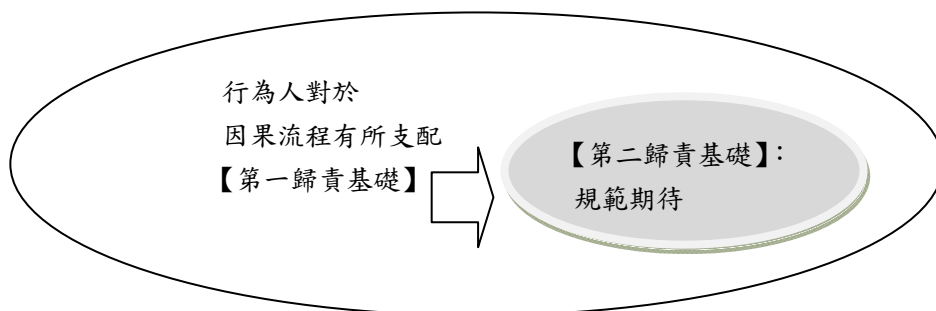


圖1 本文對於保證人地位實質根據的建構和判斷次序
(前提—後續關係)

資料來源：本文製圖。

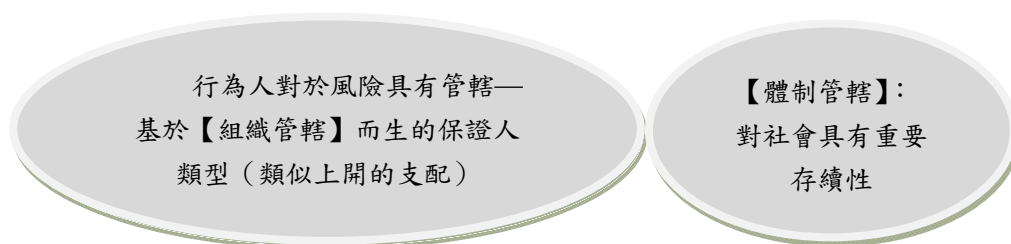


圖2 德國Jakobs教授對於保證人地位實質根據之雙重建構
(平行關係)

資料來源：本文製圖。

(三) 理論的具體內涵

行文至此，大致底定本文對於保證人地位實質根據的立場，亦即，本文反對單純由信賴、社會期待或支配來得出保證人地位之根據，蓋這些理論僅僅提供結論，而沒有敘明理由；另一方面，純粹

規範論如Jakobs的管轄理論也不可採，蓋該理論只問規範本身，而沒有反過來追問規範背後的意義，導致該理論恣意性極大，幾乎是任人填補。本文較贊同的毋寧是周滢沂教授提出的補助性的管轄和風險合意移轉管轄理論，但細部建構和理論前提仍然有所差異。首先我們要確定的是，刑事不法歸責必須是建構於行為人事實上得以支配的前提下，這也是本文對於不作為犯的基本立場——和作為犯的差異僅僅在於「規範上」的差異而非「自然現象上」的區別，說得更清楚一點，本文認為，原則上本文提及的「第一歸責基礎」是作為犯和不作為犯的共同元素。然而，正如同許多學者對於支配概念流於恣意、又或是倒果為因的批判，此處必須限制在行為人對於因果流程具有實際上的掌控，方足當之，上開Schünemann教授提出的「電影院案」的父母，在本文看來，對於家中的兒女即不具有實際的支配；或許有人會追問，難道父母不會打通電話回家關心嗎？（同樣情形可能發生於上面提及的，在峇里島過二度蜜月的父母），然而，這些都僅僅屬於「規範的支配」、「支配的可能性」，無法成為刑法應該歸責的對象²³⁸。

再者，本文的「第二歸責基礎」依上開所述，是現實上行為人對於事件的因果流程有所支配後，方進入此一規範性的審查，此也回應了作為犯和不作為犯的不同點——並非現象上的「有或無」，而是規範期待上的評價。本文認為，此規範期待必須回到刑法義務本

²³⁸ 學說上有批評Schünemann的「對結果發生的原因有支配」不應該是事實的支配，毋寧應是規範的支配，vgl. Vogel (Fn. 114), S. 352；周滢沂（註5），頁217。本文必須替Schünemann辯護：雖然Schünemann並未一貫性地堅持事實上的支配，而在「電影院案」以及部分案例透露出規範性的影子，批評已如前述，但本文必須指出，將支配理解成規範性並非一正確的理解，蓋為何單純有刑法以外的法規範義務，我們就可以毫無保留地援引作為刑事不法的處罰根據？顯然是有問題的。其實，在本文的脈絡下，現實上的支配毋寧是作為犯和不作為犯的共通歸責要件（並非如Schünemann直接當作保證人的「根據」，而是第一個首要的歸責檢驗步驟），倘若具備了，再進入作為犯和不作為犯的不同點——「第二歸責基礎」的審查，在後者，方得以考量規範性的要素。

身做為準繩，而非直接地擷取自民法或行政法源，否則就是倒退回形式法律義務理論，以舉例代替說理。首先要予以確定的是，在自由法哲學下，必須清楚地劃分道德義務和法律義務二者的界限²³⁹，尤其是刑法領域更是如此。本文認為連帶性義務（Solidaritätspflicht）或是社群主義的福祉（Wohl）都不是和自由主義的法哲學應予容忍或整合的，在非極權國家下，一個人原則上係基於個人自主（Autonomie）開展個人的生活，倘若刑法典課予人們過多積極性的義務擬創造一個看似達到完美境界的社會表象，那麼將大幅限縮人們的行動自由，20世紀諸多令人聞風喪膽的政權正是以此擬改造社會，結果當然是得不償失！準此，體制（institution）的建立必須對廣泛的連帶義務加以排斥，也不能如同Jakobs或Pawlik以「對社會存續具有重要性」如此空泛模糊、具高度恣意操控可能的用語來加以建構。

本文認為，學說提出的「補助性體制」頗值參考，蓋原則上於自由法秩序核心思考下，人們不需要為他人擔保危險的排除，只需要顧好自身即可，這也意味著，每個人應該要自我克服生活上的挑戰。然而，在某些情形下，人們無法自我管控風險，例如未成年的兒童或是身心障礙、受到監護宣告之人，這些情形成為自我負責風險的例外，或是也可以換句話說，為自我負責風險的前提，在此一情狀之下，有限度地納入所謂規範性期待、角色期待的思維。例如，學說上Seelmann正確地指出，法秩序的核心原則來自於行為負責原則，而德國刑法第13條第1項也無法脫離行為義務（Handlungspflichten）來做解釋²⁴⁰，Seelmann認為，行為義務必須以某些義務存在為前提，這些義務便是支撐行為負責原則不可或缺

239 Vgl. Kurt Seelmann, in: Niggli/Wiprächtiger (Hrsg.), Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. I, 3. Aufl., 2013, Vor § 11 Rn. 37.

240 Vgl. Kurt Seelmann, in: Neumann/Puppe/Schild (Hrsg.), Nomos Kommentar zum Strafgesetzbuch, 1995, § 13 Rn. 48; Grünwald (Fn. 172), S. 28.

的元素²⁴¹，如此前提，可以在父母親與未成年子女與國家照護安全義務（staatliche Obhut- oder auch Sicherungspflichten）間尋得²⁴²。本文認為此見解應屬可採，因為吾人在自由法秩序下，並無法證立廣泛的風險連帶性義務，唯有在不偏離自由法秩序的核心前提—自我負責、行為負責下，來對於仍無法自我負責之個體建立一補助性的防護網，輔助其於無助情境下得以脫離險境，俾該個體得以順利進入自我負責之情境，故Seelmann教授稱其為條件性、前提性的保證人義務（Voraussetzungs-Garantenpflicht）²⁴³。

準此，本文認為，自我負責之補助性體制原則上得以做為保證人地位的「第二歸責基礎」的一種類型，也是基本類型，在此應特別留意的是，本文反對「直接」地援引刑法以外的法規範作為證成保證人地位。我國學者即正確地指出，保證人地位的來源並不會是刑法以外的法律規定形式，而是可被該法律規定所表徵的體制性關係²⁴⁴，此見解相當正確地擺脫了學界長期籠罩於形式法律義務理論而無法自拔的窘境。準以此言，以此來檢討現今通說所承認的保證人類型，便可相當程度的限縮過度寬泛的保證人地位。以通說承認的「密切生活關係」類型而言，多數意見肯認共同生活的家庭成員，如父母子女、兄弟姊妹、配偶、共同生活的未婚夫妻得以成立保證人地位²⁴⁵，然而，倘若由本文所支持的，以補助性體制的觀點出發，恐怕只有未成年的子女和父母之間、或是一方受監護或輔助宣告的情形，方得以建構此一關係。其他情形，例如夫妻雙方均為成年之人，二人依照自我負責原則，需要自我克服風險，故無論是

241 Vgl. Kurt Seelmann, Opferinteressen und Handlungsverantwortung in der Garantenpflichtdogmatik, GA 1989, S. 241 (255 f.); Seelmann (Fn. 240), § 13 Rn. 135.

242 Seelmann (Fn. 240), § 13 Rn. 135.

243 Seelmann (Fn. 241), S. 255; 周漾沂（註5），頁241。

244 參見周漾沂（註5），頁242。

245 僅參見林東茂（註2），頁1-171。另外，文獻上也有承認同性伴侶得以建構保證人義務者，vgl. Kristian Kühl, Strafrecht Allgemeiner Teil, 6. Aufl., 2008, § 18 Rn. 63.

感情和睦的夫妻之間，抑或是分居的夫婦，都互相不具有保證人義務²⁴⁶；又或如學說所爭執的，密切生活的同居人是否具有保證人地位，依照本文的看法，依然不具有保證人地位，故學說上有區分類似婚姻關係以及學生同住於學生宿舍的情形，認為前者具保證人義務，後者則否的見解，在本文脈絡下，是值得再加以檢討的²⁴⁷。另外，民法親屬編的最近親屬之間（民法第1114條規定），負有扶養義務，是否也同樣地負有刑法上的保證人義務呢？答案是否定的，蓋依照本文見解，縱使親屬一方陷入困境而無法自力生活，也僅只課予他方有民法上的扶養義務，而不許由刑法介入干涉，否則即可能破壞風險自我承擔、自我負責的基本原則，而這也是傳統形式法律義務理論和本文迥異之處（前者認為民法上的法義務即應該毫無保留地援引至刑法義務上）。

其次應探討的是學說上爭議最大的「危險前行為」類型的保證人地位，按我國刑法第15條第2項：「因自己行為致有發生犯罪結果之危險者，負防止其發生之義務」之規定，係為數眾多的保證人類型中，唯一明白地被實證法所承認的，我國多數見解也肯認此一保證人事由，僅僅在「前行為的範圍」上有不同的解讀²⁴⁸；然而，學說上仍有反對此一類型的聲音存在，此見解稱為「反危險前行為理論」（*Antiingerenztheorie*），例如Schünemann由其支配理論出發，認為行為人於前行為之「後續的不作為」已經不具備現實、實際的支配，僅僅具有潛在的支配可能性（結果的防止可能性），不足以支撐歸責的基礎²⁴⁹；許玉秀教授也於文章中反對前行為類型的保證人地位，其主要的理由在於重覆評價禁止以及法條矛盾，氏認為，倘若我們認為製造危險前行為之行為人均具有救助「義務」，那麼即

246 反對看法，參見許玉秀（註133），頁89。

247 林山田（註1），頁253。

248 關於不同的學說意見，文獻整理已見，蔡聖偉，論故意不法前行為所建構之保證人義務，收於：刑法問題研究（一），頁221以下（2008年）。

249 Schünemann, Grund und Grenzen (Fn. 7), S. 316.

和刑法第27條的中止未遂規定有所扞格，蓋後者之規定，學說上沒有異議的是，行為人的中止行為必須出於「己意」始可；再者，如果今天我們承認了危險前行為保證人類型，則必須在故意未遂行為有成立中止可能時，都成立一個不作為的既遂罪，倘若貫徹了此一主張，則中止行為不但不會享有必減免的寬典，反而在未利用中止之機會防止構成要件實現時，應對於行為人加重處罰，這和刑法第27條的立法本意明顯不符²⁵⁰。

關於上開意見的妥適性與否，由於國內已有學者針對此一論點提出質疑²⁵¹，且本文並非探討前行為保證人地位的專文，故暫不擬於此評析。本文關懷的重心毋寧在於，在建構一套符合自由法哲學的補助性體制理論後，能否容納前行為類型的保證人地位，就此，本文認為，我們必須理解的是，前行為的「作為」屬於本文建構之「第一歸責基礎」的範疇，然而，就後續的不為是否也是消極義務，或僅僅如學者所言，為「消極義務的附隨性作為」呢？本文認為值得商榷，蓋就補助性體制的觀點而言，對於已經從事前行為的行為人而言，其已經製造了被害人一個無法或難以自我管轄風險的情境，此時於規範評價上，應該邏輯一貫地納入補助性體制的範疇，而非將其劃歸為消極義務，並以附隨義務加以詮釋。相同的情形也可以套用於通說承認的「危險源監督」類型之保證人地位，行為人於持有危險源的情形下，屬於對於危險源現實上具有支配，得以掌控風險不被輸出，係「第一歸責基礎」——消極義務的範疇，然而，倘若行為人放任系爭危險源輸出風險（例如放任豢養之狼犬奔跑，導致路人受傷），此時被害人已經處於一無助狀態，其屬於難以自我管控風險之情形，法規範就必須課予行為人一救助義務，來建構一補助性的體制，準此，本文認為，無論是前行為抑或是危險源監督類型的保證人地位，均可以劃歸到積極義務——補助性的法

250 許玉秀，保證人地位的法理基礎（註3），頁109-110。

251 蔡聖偉（註248），頁236以下。

體制的招牌之下（相對地，周滢沂教授和Jakobs則將其劃歸於消極義務範疇，已如前述），而我國刑法第15條第2項即為建構該體制的宣示，其他則如刑法第185條之4肇事逃逸罪之規定，也復如此²⁵²，承認前行為類型的Roxin教授也指出，法秩序既然已經要求受規範之行為人不得輸出風險以防止法益受到侵害，那麼也沒有理由在行為人已然輸出對他人造成法益侵害之風險時，反不須防止該風險進一步發展成為實害²⁵³。當然，承認危險前行為類型保證人地位，必須面對的質疑聲浪如：是否有重覆評價的疑慮？是否和中止未遂的規定相衝突？是否在每一個作為犯（未遂犯）成立時，均另外論一個不作為的既遂罪？那麼和期待可能性的衝突又如何調合呢？擬回應這些質疑，工程相當浩大，宥於篇幅，僅能於來日以專文呈現了。

最後要詳加討論的是，除了在被害人非自願地陷於無助情境（如嬰幼兒或上開的前行為、危險源監督類型），刑法須建構一補助性體制來保護被害人外，還有沒有其他情形，得以動用刑法來加以建構積極義務呢？本文認為，在自由法秩序的風險自我負責原則下，原則上每個人必須克服自身所面臨的風險，在社會多數人之間並無法建立風險連帶，然而，在社會生活交往的實際運作下，有時候個人實無法對於瞬息萬變的風險社會有著完全的掌控，此時，局部的社會連帶便是可供吾人考慮的，這也是早期Mill式的古典自由主義轉向修正自由主義或局部社群主義的嘗試。然而，「局部的社會連帶」應該如何證成呢？本文支持周滢沂教授的說法，氏由法哲學的觀點出發，除了原始取得得以被認許為正當之權利外，唯有「承繼取得」方能被認為是正當地取得權利之方法，相對地，風險的管轄也是基於相同的理解，蓋風險是權利、行使自由而來的成本，自

252 相反地，有學者以平等原則出發，認為刑法第185條之4是一歧視交通路人的立法，已經違憲，參見許玉秀，擇一故意與所知所犯——兼論違憲的肇事逃逸罪，台灣本土法學雜誌，13期，頁197-198（2000年）。

253 Roxin (Fn. 7), § 32 Rn. 150 f.

然也是權利的代價，二者必然相互連結，不可分割。準以此言，氏以「風險合意管轄」作為建立局部性連帶體制的正當理由²⁵⁴。

在這種理解下，吾人必須精準地掌握，何謂「合意」，本文認為，原則上必須二人之間有一明確的約定始可，通說將其劃歸至「依契約類型」的保證人地位；然而，有些特殊情形則不然，如救生員立於岸邊等待，下水遊戲的遊客不須親自詢問救生員的意向。本文擬強調的是，所謂的「明確的約定」必須是事實上的移轉動作才可行，倘若今天甲和乙口頭約定擬前往中央山脈縱走，並已互相約定彼此有承擔對方風險的義務，結果乙當天因為感情因素而未依該口頭約定成行，倘若甲果真因為失溫而死，此時得否歸咎予乙呢？答案應該是否定的，蓋「事實上的風險移轉」並非建立於二人之間的口頭約束，毋寧應該建立於攀登高山此一事實行為²⁵⁵，而上述救生員立於岸邊的行為，也已經進入通說所謂的事實上承擔保護功能（*tatsächliche Übernahme der Schutzfunktion*）類型的保證人情境。另外，誠如多數意見所言，契約是否依照民法第153條生效，並非討論的重點，蓋本文已經指出，民法上的法義務並無法逕自得出刑法上的保證人義務。林山田教授於教科書中所舉之例可以說明本文的想法：氏指出，一位已經遭到雇主解雇的救生員A，仍舊繼續前往岸邊等待溺水遊客，希望施予援手的行為能夠再次獲得雇主之青睞而重新聘僱，一日，B溺水，該救生員A卻因為與B之宿怨而不願就助，導致B溺斃，此時救生員A是否構成不作為殺人既遂罪？答案無非是肯定的，蓋A事實上已經承擔該風險，風險業已移轉到其身上了²⁵⁶。當然，這類型的保證人地位—風險合意、事實上承擔的管轄，其範圍僅止在承擔的範圍內生效，超過承擔的範圍（例如救生員對於泳客於岸邊之財物遭到竊取），並不生移轉管轄的

254 周漾沂（註5），頁246-247。

255 結論上相同，參見林山田（註1），頁253。

256 林山田（註1），頁251-252。

效力，而應該回歸適用風險自我負責原則。當然，此處移轉管轄之風險，並不限於自身之風險，移轉管轄他人之風險也屬之，例如父母有照料其嬰兒的原初責任，已如上述，但父母仍然得以將風險移轉給保姆或是其他親戚、友人或鄰居管轄，應不待言之。

另外，由本文的脈絡也可得知，本文對於通說所謂的「危險共同體」類型的保證人地位也非一概地予以承認，而毋寧也要回歸上述風險合意移轉與否的實質判斷。蓋在複數行為人並沒有互相承諾移轉風險下，刑法倘若強制介入該等行為人必須為他人負責，那麼就已然逸脫了自由法秩序的框架，而邁入全面性的社會連帶，集體主義將凌駕自由主義，恐大幅度地壓縮社會成員的行為自由。不過多數的危險共同體（如相約攀登中央山脈、或三五好友共同泳渡日月潭）恐怕於事前都有明示合意互相移轉風險或事實上承擔風險，故在此一前提下，得以肯認危險共同體類型的保證人地位。

總歸上述，本文的「第二歸責基礎」可以包括二種子類型——補助性體制的建立以及風險的事實上承擔²⁵⁷。

257 匿名審查意見對本文將前行為保證人類型拉到第二歸責基礎下提出質疑：「其一，危險前行為並非如作者所宣稱的，均會使他人陷入無助狀態，例如行為人在路上挖坑，路人仍然保有注意不掉進坑洞的能力；行為人開車肇事，傷勢輕微的受害者仍保有自救能力。因此，除非作者重新詮釋危險前行為概念，否則無法逕行斷定，危險前行為一律會使他人處於無助狀態，法律上就成為無自我負責能力之人。其二，即使危險前行為使他人處於無助狀態，其亦不同於父母對子女之教養義務，係已經存在於法律中、具有拘束力的「體制」，因而成為保證人地位的來源。」誠然如審查意見所言，危險前行為並不一定會使他人處於無助狀態，法律上成為無自我負責能力之人，但本文認為，第一，無助狀態或是能否自我負責是否要如此嚴格詮釋，容有疑問，蓋未成年子女按照本文見解，亦為補助性體制所及的法主體，但實際上許多未成年子女思慮甚周，甚至智識水平不會低於部分成年人，但本文仍將其納入補助體制中的理由在於未成年子女有高度可能性會陷入需要仰賴的情境，危險前行為亦然，本文在意的是一種高度倚賴性、一種課予法主體於被害人非自願陷入風險時的補充性義務；第二，刑法第15條第2項在本文看來，正好是立法者宣示每一個製造危險前行為的法主體，都應該防止危險擴大的體制，故應不會有審稿人的疑慮。

肆、結論

以下分點整理本文對於保證人地位法理基礎所做出的研究成果：

1. 除了早年Armin Kaufmann的功能理論外，關於保證人地位之法理基礎，學說上大致可以分為三個脈絡，一是信賴原則的存有論結構，二是偏向規範論的論述模式，最後則是調合存有和規範，以事物本質的折衷方法論來去尋求實質之「法的發現」。本文認為，信賴原則過於恣意不確定；支配理論僅能作為作為犯和不作為犯的等價性標準，是一個「共通點」的尋求而無法完滿回答實質依據的問題；而許玉秀教授的開放和閉鎖關係雖然別出心裁，然對於實質根據並沒有提供更好的解答；Jakobs的組織管轄和體制管轄雖然正確地由消極義務和積極義務出發，來建構刑法上的義務，然而，對於不設一定前提的體制管轄，恐怕就是倒退回形式法律義務理論，取決於法律適用者的恣意；最後則是周滢沂教授以自由法秩序的補助性體制和風險管轄合意移轉來重新建構保證人地位法理基礎，本文原則上贊同其大方向，然而，細部的理論建構仍有所差距。

2. 本文認為，作為和不作為是人們觀察事物角度的不同，而不是在於它們事物本質上的差異，本文採取的毋寧是一種規範評價上的視角來區辨二者。

3. 本文對於保證人地位的法理基礎的建構，可以分為二個步驟來加以檢驗，首先，我們必須理解作為和不作為並無本質上之迥異，故其共通點在於行為人對於因果流程的實際的、事實上的支配，這就是本文所稱的「第一歸責基礎」；其次，倘若行為人符合「第一歸責基礎」之後，即必須進入「第二歸責基礎」——規範性期待的檢驗，這部分即為作為犯和不作為犯評價上的差異，也是刑法於多大範圍應該承認積極義務，並藉以建構體制來保護被害人的問題。是以，本文對於保證人地位法理基礎的重構，並不一味地倒

向存有論，也不過度地單單由規範性視角演繹出結論，反而是有階段性地，調合二者而取得和諧。

4. 本文提及的「第一歸責基礎」是作為犯和不作為犯的共同元素。然而，正如同許多學者對於支配概念流於恣意、又或是倒果為因的批判，此處必須限制在行為人對於因果流程具有實際上的支配，始足當之。例如「電影院案」的父母，在本文看來，對於家中的兒女即不具有實際的支配；或許有人會追問，難道父母不會打通電話回家關心嗎？然而，這些都僅僅屬於「規範的支配」、「支配的可能性」，無法成為刑法應該歸責的對象。

5. 本文的「第二歸責基礎」可以包括二種子類型——「補助性體制」的建立以及「風險的事實上承擔」。關於「補助性體制」是風險自我負責、風險自我管轄的例外，在某些情形下，人們無法自我管控風險，例如「未成年的兒童」或是「身心障礙」、「受到監護宣告之人」，這些情形成為自我負責風險的例外，或是也可以換句話說，為自我負責風險的前提。另外，本文承認就補助性體制的觀點而言，對於已經從事危險前行為的行為人而言，其已經製造了被害人一個無法自我負責、自我管控風險的情境，此時於規範評價上，應該邏輯一貫地納入補助性體制的範疇。相同的情形也可以套用於通說所謂的「危險源監督」類型之保證人地位，行為人於持有危險源的情形下，屬於對於危險源現實上具有支配，得以掌控風險不被輸出，係「第一歸責基礎」——消極義務的範疇，然而，倘若行為人放任系爭危險源輸出風險，此時被害人已經處於一無助狀態，其屬於無法自我管控風險之情形，法規範就必須課予行為人一救助義務，來建構一補助性的體制。

6. 在「第二歸責基礎」之下，另有「風險的事實上承擔」此一實質根據。「風險的事實上承擔」的基礎在於風險的「合意」移轉管轄，雖然風險自我負責是大原則，然而，有些高風險的活動仍不

得不建立局部的社會連帶性，此時唯有行為人「合意」將風險移轉予他人管轄方可建構此一體制，來規制行為人。這種體制並不需要一個民法上生效的契約為前提，毋寧應由「事實上」的視角加以觀照，故通說所謂的「事實上承擔」應予贊同。另外，「危險共同體」類型的保證人地位則按本文脈絡，非一概地予以承認，而毋寧也要回歸風險合意移轉與否的實質判斷。

參考文獻

1. 中文部分

- Arthur Kaufman著，吳從周譯、顏厥安審校（2003），類推與「事物本質」——兼論類型理論，臺北：新學林。[Kaufmann, Arthur (1982), *Analogie und „Natur der Sache“: Zugleich ein Beitrag zur Lehre vom Typus*, 2. Aufl., Heidelberg: Decker & Müller.]
- Bernd Schüneman著，陳志輝譯（2006），德國不作為犯法理的現況，收於：許玉秀、陳志輝編，不疑不惑獻身法與正義——許迺曼教授刑事法論文選輯，頁629-668。[Schünemann, Bernd (1995), *Zum gegenwärtigen Stand der Dogmatik der Unterlassungsdelikte in Deutschland*, in: Gimbernat/Schünemann/Wolter (Hrsg.), *Internationale Dogmatik der objektiven Zurechnung und Unterlassungsdelikte. Ein spanisch-deutsches Symposium zu Ehren von Claus Roxin*, Heidelberg: Decker & Müller, S. 49-82.]
- Immanuel Kant著，李明輝譯（1990），道德底形上學之基礎，臺北：聯經。[Kant, Immanuel (1785), *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten*, Riga: Hartknoch.]
- （2015），道德底形上學，臺北：聯經。[Kant, Immanuel (1797), *Die Metaphysik der Sitten*, Königsberg: bey Friedrich Nicolovius.]
- Jim Holt著，陳信宏譯（2016），世界為何存在？，臺北：大塊文化。[Holt, Jim. 2013. *Why Does the World Exist?: An Existential Detective Story*. New York, NY: Liveright.]
- 山口厚著，付立慶譯（2011），刑法總論，北京：中國人民大學出版社。[山口厚（2007），*刑法總論*，2版，東京：有斐閣。]
- 西田典之著，王昭武、劉明祥譯（2012），日本刑法總論，臺北：

- 元照。[西田典之（2010），刑法總論，2版，東京：弘文堂。]
- 許玉秀譯（1987），1984年開羅第13次國際刑法會議決議，刑事法雜誌，31卷3期，頁77-95。
- 王效文（2015），刑罰目的與刑法體系——論Günther Jakobs功能主義刑法體系中的罪責，成大法學，30期，頁151-222。
- 古承宗（2015），保證人地位之實質準據（與談稿），收於：公益信託東吳法學基金編，不作為犯的現況與難題，頁358-368，臺北：元照。
- 李自強（2015），暴力犯罪之社會與環境因素，收於：楊士隆編，暴力犯罪：原因、類型與對策，3版，頁95-111，臺北：五南。
- 車浩（2015），保證人地位的實質根據，收於：公益信託東吳法學基金編，不作為犯的現況與難題，頁199-292，臺北：元照。
- 余振華（2011），刑法總論，臺北：三民。
- 林山田（2008），刑法通論（下），10版，臺北：元照。
- 林東茂（2012），刑法綜覽，7版，臺北：一品。
- 林鈺雄（2002），刑法之運用與解釋（上），月旦法學教室，2期，頁62-71。
- （2011），新刑法總則，3版，臺北：元照。
- 周漾沂（2012），論攻擊性緊急避難之定位，臺大法學論叢，41卷1期，頁403-444。
- （2014），重新建構刑法上保證人地位的法理基礎，臺大法學論叢，43卷1期，頁209-269。
- （2014），刑法上作為與不作為之區分，科技法學評論，11卷2期，頁87-129。
- （2018），反思信賴原則的理論基礎，收於：陳子平教授榮退論文集編輯委員會編，法學與風範——陳子平教授榮退論文集，頁51-62，臺北：元照。
- 苑舉正（2007），從方法論的角度論維根斯坦與波普的「否定」概

念，台灣哲學會2007年度學術研討會，東海大學主辦，2007年10月20-21日。

徐育安（2015），不作為犯之因果關係，收於：公益信託東吳法學基金編，不作為犯的現況與難題，頁160-180，臺北：元照。

高金桂（2012），不作為犯與保證人義務，軍法專刊，58卷5期，頁146-167。

涂紀亮編（2003），維特根斯坦全集（一），中國：河北教育出版社。

陳子平（2005），刑法總論（上），臺北：元照。

陳志輝（2004），義務犯，月旦法學教室，23期，頁34-38。

——（2012），身分犯之正犯的認定——以德國義務犯理論為中心，政大法學評論，130期，頁331-418。

——（2015），刑法保證人地位法理根據之分析，收於：公益信託東吳法學基金編，不作為犯的現況與難題，頁293-350，臺北：元照。

陳慈陽（2016），憲法學，3版，臺北：元照。

許玉秀（1997），最高法院七十八年台上字第三六九三號判決的再檢討——前行為的保證人地位與客觀歸責理論初探，收於：主觀與客觀之間，頁281-324，臺北：自版。

——（1997），前行為保證人類型的生存權？——與結果加重犯的比較，收於：主觀與客觀之間，頁379-441，臺北：自版。

——（1997），論西德刑法上保證人地位之實質化運動，收於：主觀與客觀之間，頁325-378，臺北：自版。

——（1997），走出主觀與客觀的迷思——一個（不（太）不）謙虛的嘗試，收於：主觀與客觀之間，頁1-44，臺北：自版。

——（2000），實質的正犯概念，收於：刑法的問題與對策，2版，頁1-64，臺北：學林出版。

——（2000），保證人地位的法理基礎，收於：刑法的問題與對策，2版，頁65-120，臺北：學林出版。

- (2000)，擇一故意與所知所犯——兼論違憲的肇事逃逸罪，台灣本土法學雜誌，13期，頁186-199。
- (2000)，犯罪階層體系及其方法論，臺北：春風煦日論壇。
- (2002)，當代刑法理論之發展，收於：王兆鵬編，當代刑事法學之理論與發展——蔡墩銘教授榮退感念專輯，頁1-73，臺北：新學林。
- (2002)，夫妻間之保證人地位——兼論通姦罪——評釋九十年臺上一五六號、九十年臺上更(一)字第九四號、八十六年度上訴字第三九八六號、八十七年度訴字第一五六五號判決，台灣本土法學雜誌，39期，頁79-92。
- 許恒達(2016)，行為非價與結果非價——論刑事不法概念的實質內涵，收於：法益保護與行為刑法，頁79-155，臺北：元照。
- 許澤天(2015)，不純正不作為犯的正犯判斷標準，收於：公益信託東吳法學基金編，不作為犯的現況與難題，頁411-471，臺北：元照。
- 黃榮堅(2000)，論保證人地位，收於：刑罰的極限，頁19-56，臺北：元照。
- (2012)，基礎刑法學(下)，4版，臺北：元照。
- 蔡芸琦(2018)，保證人地位之判斷模式，收於：陳子平教授榮退論文集編輯委員會編，法學與風範——陳子平教授榮退論文集，頁235-261，臺北：元照。
- 蔡聖偉(2008)，論故意不法前行為所建構之保證人義務，收於：刑法問題研究(一)，頁221-256；臺北：元照。
- (2015)，作為與不作為的區分(與談稿)，收於：公益信託東吳法學基金編，不作為犯的現況與難題，頁106-118，臺北：元照。
- 鄭逸哲(2010)，構成要件理論與構成要件適用：刑事法學及其方法(二)，2版，臺北：自版。

2. 外文部分

- Blei, Hermann (1966), Garantenpflichtbegründung beim unechten Unterlassen, in: Geerds/Naucke (Hrsg.), Festschrift für Hellmuth Mayer, Berlin: Duncker & Humblot, S. 119-144.
- Brammsen, Joerg (1986), Die Entstehungsvoraussetzungen der Garantenpflichten, Berlin: Duncker & Humblot.
- (1989), Erfolgszurechnung bei unterlassener Gefahrverminderung durch einen Garanten, MDR, S. 123-127.
- Dahm, Georg (1940), Bemerkungen zum Unterlassungsproblem, ZStW 59, S. 133-183.
- Engisch, Karl (1963), Logische Studien zur Gesetzanwendung, 3. Aufl., Heidelberg: C. Winter.
- Gierhake, Katrin (2013), Der Zusammenhang von Freiheit, Sicherheit und Strafe im Recht: Eine Untersuchung zu den Grundlagen und Kriterien legitimer Terrorismusprävention, Berlin: Duncker & Humblot.
- Greco, Luís (2005), Das Subjektive an der objektiven Zurechnung: Zum „Problem“ des Sonderwissens, ZStW 117, S. 519-554.
- (2011), Kausalitäts- und Zurechnungsfragen bei unechten Unterlassungsdelikten, ZIS 8-9, S. 674-691.
- Grünwald, Anette (2001), Zivilrechtlich begründete Garantenpflichten im Strafrecht?, Berlin: Duncker & Humblot.
- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1986), Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Herzberg, Rolf Dietrich (1972), Die Unterlassung im Strafrecht und das Garantprinzip, Berlin: de Gruyter.
- Hirsch, Andreas von /Neumann, Ulfrid/Seelmann, Kurt (Hrsg.) (2013),

- Solidarität im Strafrecht: Zur Funktion und Legitimation strafrechtlicher Solidaritätspflichten, Baden-Baden: Nomos.
- Jakobs, Günther (1983), Strafrecht Allgemeiner Teil, Berlin: de Gruyter.
- (1989), Tätervorstellung und objektive Zurechnung, in: Dornseifer/Horn/Schilling (Hrsg.), Gedächtnisschrift für Armin Kaufmann, Köln: Carl Heymanns, S. 271-288.
- (1993), Strafrecht Allgemeiner Teil, 2. Aufl., Berlin: de Gruyter.
- (1996), Die Strafrechtliche Zurechnung von Tun und Unterlassen, Opladen : Westdeutscher Verlag.
- (2002), Vorangegangenes Verhalten als Grund eines Unterlassungsdelikts: Das Problem der Ingerenz im Strafrecht, Akademie-Journal 2, S. 8-10.
- Jescheck, Hans-Heinrich (1993), in: Jähnke/Laufhütte/Odersky (Hrsg.), Leipziger Kommentar Strafgesetzbuch, 11. Aufl., Berlin: de Gruyter, § 13.
- Jescheck, Hans-Heinrich/Weigend, Thomas (1996), Lehrbuch des Strafrechts: Allgemeiner Teil, 5. Aufl., Berlin: Duncker & Humblot.
- Kahlo, Michael (2001), Die Handlungsform der Unterlassung als Kriminaldelikt, Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann.
- (1968), Die Metaphysik der Sitten, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- Kaufmann, Armin (1988), Die Dogmatik der Unterlassungsdelikte, 2. Aufl., Göttingen: Schwartz.
- Kaufmann, Arthur (1982), Analogie und „Natur der Sache“: Zugleich ein Beitrag zur Lehre vom Typus, 2. Aufl., Heidelberg: Decker & Müller.
- Krahl, Matthias (1999), Tatbestand und Rechtsfolge, Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann.

- Kühl, Kristian (2008), *Strafrecht Allgemeiner Teil*, 6. Aufl., München: Vahlen.
- Larenz, Karl (1991), *Methodenlehre der Rechtswissenschaft*, 6. Aufl., Berlin: Springer.
- Luhmann, Niklas (2008), *Rechtssoziologie*, 4. Aufl., Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Mackie, John Lesile. 1974. *The Cement of the Universe: A study of Causation*. Oxford: Oxford University Press (Clarendon Press).
- Maiwald, Manfred (1979), Besprechung von H.H. Kühne's Betrug, ZStW 91, S. 923-987.
- Nagler, Johannes (1938), Die Problematik der Begehung durch Unterlassung, GS 111, S. 1-123.
- Otto, Harro (2004), *Grundkurs Strafrecht: Allgemeine Strafrechtslehre*, 7. Aufl., Berlin: de Gruyter.
- Pawlik, Michael (1995), Unterlassene Hilfeleistung: Zuständigkeitsbegründung und systematische Struktur, GA, S. 360-372.
- (2011), „Das dunkelste Kapitel in der Dogmatik des Allgemeinen Teils“: Bemerkungen zur Lehre von den Garantenpflichten, in: Heinrich/Jäger/Achenbach/Amelung/Bottke/Haffke/Schünemann/Wolter (Hrsg.), *Strafrecht als Scientia Universalis* (Festschrift für Claus Roxin), Berlin: de Gruyter, S. 931-945.
- (2012), *Das Unrecht des Bürgers*, Tübingen: Mohr Siebeck.
- Puppe, Ingeborg (2013), in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen (Hrsg.), *Nomos Kommentar zum Strafgesetzbuch*, 4. Aufl., Baden-Baden: Nomos, Vor § 13.
- Roxin, Claus (1993), in: Jähnke/Laufhütte/Odersky (Hrsg.), *Leipziger Kommentar Strafgesetzbuch*, 11. Aufl., Berlin: de Gruyter, § 25.

- (2003), *Strafrecht Allgemeiner Teil*, Bd. II: Besondere Erscheinungsformen der Straftat, München: C. H. Beck.
- (2006), *Strafrecht Allgemeiner Teil*, Bd. I: Grundlagen. Der Aufbau der Verbrechenslehre, 4. Aufl., München: C. H. Beck.
- (2006), *Täterschaft und Tatherrschaft*, 8. Aufl., Berlin: de Gruyter.
- Rudolphi, Hans-Joachim (2007), in: Wolter (Hrsg.), *Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch*, 7. Aufl., Köln: Carl Heymanns, § 13.
- Sánchez-Vera, Javier (1999), *Pflichtdelikt und Beteiligung*, Berlin: Duncker & Humblot.
- Sangenstedt, Christof (1989), *Garantenstellung und Garantenpflicht von Amtsträgern*, Frankfurt am Main: Peter Lang.
- Schünemann, Bernd (1971), *Grund und Grenzen der unechten Unterlassungsdelikte*, Göttingen: Schwartz.
- (1984), *Die Unterlassungsdelikte und die strafrechtliche Verantwortlichkeit für Unterlassungen*, ZStW 96, S. 287-320.
- (1993), in: Jähne/Laufhütte/Odersky (Hrsg.), *Leipziger Kommentar Strafgesetzbuch*, 11. Aufl, Berlin: de Gruyter, § 14.
- (2000), *Unternehmenskriminalität*, in: Roxin/Widmaier (Hrsg.), *50 Jahre Bundesgerichtshof, Festgabe aus der Wissenschaft*, Bd. IV. *Strafrecht, Strafprozeßrecht*, München: C. H. Beck, S. 621-646.
- Scott, William Richard, and John W. Meyer, eds. 1994. *Institutional Environments and Organizations: Structural Complexity and Individualism*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Seelmann, Kurt (1989), *Opferinteressen und Handlungsverantwortung in der Garantenpflichtdogmatik*, GA, S. 241-256.
- (1994), *Rechtsphilosophie*, München: C. H. Beck.
- (1995), in: Neumann/Puppe/Schild (Hrsg.), *Nomos Kommentar*

zum Strafgesetzbuch, Baden-Baden: Nomos, § 13.

—— (2013), in: Niggli/Wiprächtiger (Hrsg.), Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. I, 3. Aufl., Basel: Helbing Lichtenhahn, Vor § 11.

Stratenwerth, Günter/Kuhlen, Lothar (2011), Strafrecht Allgemeiner Teil, 6. Aufl., München: Vahlen.

Timpe, Gerhard (1983), Strafmilderungen des Allgemeinen Teils des StGB und das Doppelverwertungsverbot, Berlin: Duncker & Humblot.

Vogel, Joachim (1993), Norm und Pflicht bei den unechten Unterlassungsdelikten, Berlin: Duncker & Humblot.

Welp, Jürgen (1968), Vorangegangenes Tun als Grundlage einer Handlungsäquivalenz der Unterlassung, Berlin: Duncker & Humblot.

Wittgenstein, Ludwig (1922), Tractatus logico-philosophicus, online verfügbar unter <https://people.umass.edu/klement/tlp/tlp.pdf>.

Wohlers, Wolfgang/Gaede, Karsten (2013), in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen (Hrsg.), Nomos Kommentar zum Strafgesetzbuch, 4. Aufl., Baden-Baden: Nomos, § 13.

Wolff, Ernst Amadeus (1965), Kausalität von Tun und Unterlassen, Heidelberg: C. Winter.

Reflections on the Legal Grounds of Guarantor's Obligations: Between Ontology and Normativity

*Yi-Wen Huang**

Abstract

This paper aims at analyzing the legal grounds of a guarantor's position. Article 15 of Taiwan Criminal Code is basis for penalties for criminal offences committed by omission; however, the Article does not specify in what circumstances a person with the identity or status of the guarantor can be held liable for the offense of omission. Thus, theorists have developed substantive standards to determine the responsibility of the perpetrator. This paper argues that although there are theories about the legal grounds for a guarantor's position, none of them can effectively explain the substantive basis of the criminal offence committed by omission (namely, why we "should" punish a person who does not take care of others). To solve this problem and mediate the ontology and the normativity, this paper develops "Double Criteria of Imputation". In this context, we must first establish the similarities and differences between crime by commission and that by omission. I argue that the similarity between crime by commission and that by omission is that the perpetrator has substantive control over the result, which is the first step to determine whether a person can be punished or not. The difference is that criminal law should intervene actively only when the perpetrator cannot control risk themselves, and the intervention includes the establishment of a subsidy system and the risk of *de facto* commitment.

* Postgraduate student, College of Law, National Chengchi University, Major in Criminal Law.

Only when the perpetrator meets both requirements can omission under Article 15 be charged against them.

KEYWORDS: criminal offence committed by omission, guarantor's position, dominate, self-control, solidarity.